

家暴事件的正當防衛難題^{*}

——以趙岩冰殺夫案為中心

薛智仁^{**}

摘要

繼1993年的鄧如雯殺夫案之後，2006年的趙岩冰殺夫案再度凸顯出刑法的正當防衛規定在家暴事件的適用難題。本案事實審法院援引受虐婦女症候群來修正侵害現在性的判準，擴大正當防衛的適用範圍。不過，本文一方面將指出，基於正當防衛權的銳利性，應嚴格認定防衛情狀，對於侵害概念應作目的性限縮解釋，而且僅在法益陷入具體危險時始肯定現在不法侵害之存在。另一方面，防衛手段的要件應該放寬，法院應設定切合現實的防衛手段必要性標準，亦不宜承認通說在緊密的個人關係所附加之防衛手段合宜性限制。整體而言，尊重受虐婦女特殊經驗的正確方式，是詳查其真正的境遇以適用正當防衛規定，而不是為其創造特殊的正當防衛標準。

關鍵詞：正當防衛、侵害概念、侵害現在性、具體危險、受虐婦女

* 投稿日：2013年10月31日；接受刊登日：2014年5月2日。〔責任校對：向民潔〕。

本文獲得國立臺灣大學法律學院之出國研究經費補助，使作者能在2013年夏天於德國杜賓根大學歐洲當代臺灣研究中心完成初稿，並發表於同年12月11日由靜宜大學法律學系主辦之「刑法學術研討會」，作者在此感謝與談人徐偉群教授及主持人吳耀宗教授的提問及建議，以及兩位匿名審查人之寶貴意見。

** 國立臺灣大學法律學院專任助理教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/22214141.pdf>。



症候群、防衛必要性、防衛合宜性、緊密的個人關係、保證人地位、防衛過當。

目 次

壹、前言	一、防衛手段之必要性
貳、趙岩冰殺夫事件概述	二、防衛手段之合宜性
一、事實經過	(一) 緊密的個人關係作為
二、歷審判決	防衛手段之社會倫理
參、論述模式的選擇	限制
肆、防衛情狀	(二) 違反罪刑法定原則的
一、侵害概念	限制
二、侵害現在性概念	(三) 欠缺實質正當性的限
(一) 侵害現在性的判斷標	制
準	(四) 小結
(二) 考量受虐婦女的特殊	陸、防衛過當
經驗	柒、結論
(三) 小結	
伍、防衛手段	

壹、前言

我國刑法第23條：「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。」在這段簡明扼要的文字裡，不論是「現在不法之侵害」的防衛情狀，或是「出於防衛自己或他人權利之行為」的防衛手段，以及「防衛行為過當」的概念，在學說及實務上都引發了諸多解釋上的難題。

這個刑法學的基本問題，在我國因為一則受虐婦女家暴殺人案件而受到矚目。1993年10月27日，鄧如雯不甘丈夫林阿棋多年的凌虐，在氣憤之下趁著丈夫睡覺時，以鐵鎚與水果刀將其殺害。當時，本案辯護律師主張法院應該擴大適用正當防衛，但是法院認為，既然正當防衛是以存在現在不法侵害為要件，睡覺中的丈夫在被殺害之際並未對鄧如雯施加暴力，所以不符合此要件¹。因此，第一審法院仍然判決鄧如雯成立普通殺人罪，但以自首犯罪為由，將刑度減輕為5年6個月²，第二審法院另以鄧如雯精神耗弱為由，再將刑度減為3年³，二審判決在最高法院駁回鄧如雯的上訴後確定。此一判決最讓人質疑的是，如果鄧如雯不是利用林阿棋睡覺時殺死他，果真有其他從家暴解脫的出口？基於對此判決的反省，黃榮堅教授主張，侵害之現在性，所指的應該是侵害者的侵害行為已經到達防衛者最後的有效防衛時間點，而不必然僵化於所謂已經開始其侵害行為⁴。劉宏恩教授也贊同此立場，並且批評法院未考量婚姻暴力犯罪的特殊性，對長期受虐婦女可能之特有心理反應，及其居於極端弱勢的特殊處境，亦未進行必要之調查與瞭解，傳統上對於侵害現在性的解釋，顯然忽略防衛者處於絕對弱勢的情形，不能反映受虐婦女之特殊處境與經驗，有檢討變更之必要⁵。

事實上，家暴案件對於正當防衛理論所帶來的挑戰，並不僅限於重新反省不法侵害的現在性標準，也涉及防衛手段的合法界限，

-
- 1 本案判決的敘事分析：李佳玟，女性犯罪責任的敘事建構——以鄧如雯殺夫案為例，臺大法學論叢，34卷6期，頁38（2005年）。
 - 2 臺灣板橋地方法院82年度重訴字第43號刑事判決，[A_0002_0003_001]，收錄於臺灣法實證研究資料庫，法律文件資料庫。
 - 3 鄧如雯家暴殺夫案第二審判決（臺灣高等法院83年度上訴字第1970號刑事判決），[A_0002_0003_0004]，收錄於臺灣法實證研究資料庫，法律文件資料庫。
 - 4 黃榮堅，論正當防衛，收於：刑罰的極限，頁89以下、頁117以下（2000年）。
 - 5 劉宏恩，婚姻暴力受虐婦女殺夫之責任能力與違法性問題（下）——法律心理學之觀點，月旦法學雜誌，20期，頁99-100（1997年）。

最直接相關的是防衛手段的合宜性（Gebotensein）或社會倫理限制。通說認為，在特殊情況裡，一個必要的防衛手段必須額外受到社會倫理的限制，否則無法阻卻違法。其中一個公認的情形，就是在緊密的個人關係內部所發生的不法侵害。在典型的家暴案件中，不論是受暴的妻子面對施暴的先生，或是受暴的孩童面對施暴的父母，受害者（妻子或孩童）都不得對加害者（先生或父母）立即採取有效且必要的防衛手段，而是只有在無法迴避或抵擋的時候，才能夠施以侵害他方的防衛手段。從國家防治家庭暴力的立場來看，如果受害的家庭成員負有自行迴避或盡力抵擋家庭暴力的義務，不能如同面對第三人不法侵害一般採取必要的防衛手段，豈不是變相地容忍或鼓勵家庭暴力嗎？在最近親屬之間的不法侵害，這種對防衛手段的社會倫理要求，果真是一個具有正當性的限制⁶？

很不幸地，儘管鄧如雯殺夫案促成家庭暴力防治法在1999年公布施行，2006年2月1日卻再度發生一起廣受各界注目的家暴殺夫案件，受虐的中國婦女趙岩冰殺死其丈夫賈新民。在社會政策的層面，本案凸顯了臺灣社會移民婦女的居留權、工作權、健康保險等未受到充分保障，間接地釀成這樁悲劇，而在刑法學的層面，主要則是再度引發正當防衛的適用問題⁷。尤其第一、二審判決在侵害現在性的判斷上，脫離了傳統的客觀判斷標準，採納被告辯護人的主張，一併考量趙岩冰具有受虐婦女的創傷壓力症候群而肯定其係面臨現在不法侵害。對照鄧如雯殺夫案之後，法學界對於我國法院嚴格認定現在不法侵害的批評，這兩則判決突破既存實務見解的態度，也獲得來自學術界的肯定⁸。不過，本案的事實經過及歷審判決顯示，其中所牽涉的正當防衛難題，並不僅限於防衛情狀的認

6 此種限制在近年來逐漸受到挑戰：林鈺雄，新刑法總則，4版，頁256（2014年）。

7 本案同時涉及責任能力及義憤殺人的問題，則不在本文討論之列。

8 林志潔，復仇的女王蜂？精神異常的弱女子？——由女性主義法學方法評析最高法院相關裁判，台灣法學雜誌，126期，頁49（2009年）。

定，而是也牽涉到防衛手段的必要性、合宜性與防衛過當的適用標準等問題，是一個絕佳的正當防衛本土教材。因此，本文希望藉由本事件，探究其中尚未被深入分析的正當防衛難題，尤其是嘗試釐清，我國的正當防衛規定、理論及實務在家暴事件中，其不足之處究竟是在於防衛情狀的認定未考量受虐婦女的特殊認知，抑或是自始未精準掌握正當防衛的制度目的。以下本文將先概述本案的事實經過及歷審判決（下述貳），再依序就本案所牽涉的防衛情狀（下述參）、防衛手段（下述肆）及防衛過當問題（下述伍），作理論層面的檢討，最後總結本文研究成果。至於其他與本案無直接相關的正當防衛問題，則暫且不予討論。

貳、趙岩冰殺夫事件概述

一、事實經過

中國婦女趙岩冰（以下簡稱趙女）與榮民賈新民（以下簡稱賈男）結婚，居住於同一單身榮眷宿舍的上下樓，兩人因觀念差異而衝突不斷。賈男嚴格控制趙女的交友及行動自由，要求無神論的趙女信仰基督教，經常施以言詞羞辱，兩次以棍棒、椅子及抓癢棒毆打趙女，經臺北地方法院核發民事通常保護令。其間，趙女經診斷罹患子宮頸癌而住院開刀，出院後亦經常因為所裝置之導尿管滑落位移而進出醫院。上述家庭與身體因素，也導致趙女精神狀況不穩定，被診斷有受虐婦女創傷症候群，罹患重度憂鬱症。在案發當天，趙女因為多日未進食，開刀所裝置之導尿管又生問題，疼痛難耐，下樓請求賈男將其送醫就診。賈男以趙女有能力自行下樓而予以拒絕，在趙女央求其提供醫療費用時，更拿起茶几上的菜刀表明，若是再提錢的事情，就會將其「腦袋剝掉」。由於賈男過去曾多次揚言殺害之，加上此次手握菜刀威脅，趙女相信自己有性命危

險，故隨手拿起身旁鏡台上所放置的榔頭，用力敲擊賈男的頭部數下，致使賈男意識昏迷倒地。趙女見賈男昏迷倒地，便奪走賈男手上所持之菜刀，接續砍刺其臉部及頸部，賈男因為氣管、食道及左側頸動脈被切斷而當場大量出血死亡。趙女見狀，於持該菜刀前往廚房之流理臺清洗之後，自行前往派出所自首。

二、歷審判決

趙女歷經臺北地方法院⁹、臺灣高等法院二審¹⁰、最高法院¹¹撤銷發回高院更審¹²，皆以普通殺人罪（刑法第271條第1項）被判決有罪，宣告有期徒刑一年六月，全案最後經最高法院¹³駁回被告上訴而定讞。基本上，各審認定之犯罪事實相同，主要爭點圍繞在三大問題上：第一、趙女之殺人是否符合「當場激於義憤」¹⁴之減輕構成要件（刑法第273條）？第二、是否符合正當防衛之阻卻違法事由（刑法第23條）？第三、是否具有完全責任能力（刑法第19條）？針對第一個問題，歷審均認定賈男的舉止雖屬不義行為，但是尚未達「在客觀上足以引起公憤，依一般人之通常觀念，確無可容忍」的程度，故趙女的殺人不符當場激於義憤之減輕構成要件。針對第三個問題，各審法院均肯定趙女於行為時具有完全之責任能力，因為依據二個鑑定報告及一位鑑定人之陳述，趙女於行為時並未處於精神解離的狀態，其認知判斷能力並未顯著低於常人，不符合限制責任能力之要件¹⁵。判決的上述見解是否妥當，本文暫

9 臺北地方法院 95 年度重訴字第 38 號刑事判決。

10 臺灣高等法院 96 年度上訴字第 4489 號刑事判決。

11 最高法院 99 年度台上字第 5562 號刑事判決。

12 臺灣高等法院 99 年度重上更（一）字第 268 號刑事判決。

13 最高法院 100 年度台上字第 2341 號刑事判決。本判決之評釋：林孟皇，婚姻移民與家庭暴力情境下殺夫行為的法律適用——評最高法院 100 年度台上字第 2341 號刑事判決，法令月刊，63 卷 5 期，頁 25-62（2012 年）。

14 對此概念之評析：徐育安，當場激於義憤，月旦法學教室，122 期，頁 30-32（2012 年）。

15 受虐婦女殺夫的典型問題概況：林志潔（註 8），頁 37-42。

不表立場。本文所關心的是第二個問題：趙女殺人是否符合正當防衛要件？

就此，臺北地方法院¹⁶及臺灣高等法院¹⁷認定，趙女之殺人係防衛過當（第23條但書）。針對防衛情狀，上述判決認定，賈男手持菜刀威脅殺之，已該當於預備殺人罪（刑法第271條第3項），任何人均認為處於急迫之危險，故屬於現在不法之侵害。不過上述判決特別強調，防衛情狀之判斷不應僅採取一般理性人之標準，而是應該將受虐婦女之經驗納入考慮。以趙女患有受虐婦女之創傷症候群而言，其對於任何暴力徵兆會變得十分敏感，在每次被虐之情境裡，都可能相信自己面臨生命或嚴重身體傷害之立即危險，故賈男之舉動已足以使趙女相信自己將被殺死。然而，趙女持榔頭朝賈男頭部敲擊，以及後來奪下賈男手中菜刀猛刺其臉部及頸部，雖是擔心賈男反擊所為之防衛行為，卻顯已逾越當時必要之程度。因為，趙女若是持榔頭、菜刀朝賈男手部或其他不致命之身體部位揮砍，即可達到防禦嚇阻之作用。基此，趙女之殺人係面對現在不法侵害之防衛手段，但是逾越必要程度。

針對上述判決有關防衛情狀的認定，最高法院指摘：「然苟原判決上開論述說明俱屬無訛，則案發當時被害人是否並未著手於殺害上訴人之行為，即上訴人並非對被害人現在不法之侵害為防衛之行為，上訴人所為能否認屬防衛過當之正當防衛行為，尚非全無疑義，仍待調查釐清論述說明。」換言之，最高法院似乎主張，本案唯有賈男已著手殺人始符合現在不法侵害之要件，光是預備殺人行

16 針對本判決之相關討論：賴芳玉等，「從家暴受虐婦女正當防衛殺人案探討受虐婦女經驗及女性主義法學於司法實踐之可能性」座談會紀錄，全國律師，12卷2期，頁55-81（2008年）；張天一，兩岸正當防衛與防衛過當規定之比較，收於：黃陽壽、王煦棋、張天一、胡博硯編，中國大陸法制研究——第十九輯，頁141-196（2011年）。

17 本判決之評釋：高金桂，義憤殺人罪與正當防衛——臺灣高等法院九十六年度上訴字第四四八九號判決，月旦裁判時報，2期，頁118-123（2010年）。

為尚屬未來之不法侵害，無適用正當防衛及防衛過當之餘地。

本案發回更審之後，臺灣高等法院認定趙女持榔頭敲擊是防衛過當，持刀刺殺則自始非正當防衛，改以「其情可憫」（刑法第59條）作為減刑根據。在防衛情狀之判斷上，更審法院不再關注賈男的舉止是否為預備殺人，也不再強調趙女之受虐婦女經驗對正當防衛要件判斷之意義，而是綜合考慮賈男先前與趙女之激烈衝突、案發當時賈男持刀威嚇已顯示其有強烈殺意、案發現場空間狹小，趙女生命處於賈男控制範圍之內等因素，依據一般客觀社會合理通念，認定趙女之生命面臨賈男之現時不法侵害。基此，趙女持榔頭朝賈男頭部敲擊，應被評價為對現在不法侵害所為之防衛過當行為。然而，賈男頭部受到榔頭重擊之後，中樞神經受創，已意識昏迷、無法站立，故賈男不可能對趙女繼續施暴，趙女持菜刀猛刺臉部、頸部之行為，已非對現在不法侵害之防衛手段，不符合正當防衛之要件。

參、論述模式的選擇

值得注意的是，本案歷審判決針對正當防衛的論述模式不同：第一、二審判決主要基於受虐婦女經驗及賈男預備殺人，而認定趙女面臨現在不法侵害，但將趙女持榔頭敲擊與持刀刺殺視為一個整體的舉動，認定其已逾越防衛手段的必要性。在最高法院指摘二審的侵害現在性判斷不當之後，更審判決改弦更張，依個案情狀綜合認定侵害的急迫性，依舊肯定趙女面臨現在不法侵害，但是其持榔頭敲擊係防衛過當；至於趙女在賈男昏迷之後的持刀刺殺，已非正當防衛，也無防衛過當的問題。簡言之，第一、二審判決將趙女的前後兩個舉動視為一體，更審判決卻是將這兩個舉動分割評價。因此，在進入細部的分析之前，我們必須先確定哪種論述模式比較妥當。

在犯罪評價上，究竟要將一個人的所有舉動合併觀察或切割觀察，是一個目的性考量的產物。我們要將行為切割到多麼細，取決於什麼程度的行為切割，最能凸顯所要解決的實質問題，又不會使犯罪檢驗成為無意義的重複。舉例來說，行為人在一分鐘之內向被害人的臉部、頸部、胸部與腹部揮拳二十餘次，當我們評價行為人是否成立傷害罪時，是應該每一次的揮拳都拿來獨立檢驗，還是依據揮拳部位分成四個群組來檢驗，或是視為一個整體的揮拳行為來檢驗呢？理論上來說，犯罪是指某一個瞬間下的人類身體舉動完全實現犯罪的成立要件（構成要件該當性、違法性、有責性），因此最謹慎的作法就是切割每一個揮拳動作來檢驗其是否成立犯罪。不過，我們立刻就可以發現，如果從第一個揮拳動作到最後一個揮拳動作，行為人面臨的客觀情狀、造成的傷害後果、主觀的認知與情緒都沒有改變，犯罪評價上所牽涉的問題及結論完全相同，對於後面各次揮拳動作的犯罪檢驗，便會成為沒有意義的重複工作。此時比較經濟的作法就是，將所有揮拳的動作視為一個整體，一次判斷其是否成立傷害罪，不必再執著於行為人揮拳的次數及部位。然而，如果被害人在挨了幾拳之後死亡，行為人卻不知情而繼續揮拳，此時在犯罪檢驗上就必須考量到，前半段揮拳行為可能成立傷害（致死）罪，後半段揮拳行為可能成立不罰的傷害未遂，有必要將整個揮拳的過程切割觀察，分別檢驗其是否成立傷害（致死）罪。如果堅持將所有的揮拳動作視為一個整體，其結果不是使原本成立傷害罪的行為一併被評價為不罰的傷害未遂（著眼於被害人已死亡），就是使原本不罰的傷害未遂行為一併被評價為成立傷害罪（著眼於被害人尚未死亡），無論是哪種情形，都不會是實質正確的刑法評價。由此可知，在單一的犯罪事件由一個人的數個舉動組合而成時，如果事件的主客觀情狀未發生具有刑法重要性的變化，基於犯罪檢驗經濟性的考量，應該將數個舉動視為整體而作為犯罪檢驗的客體。然而，一旦事件的主客觀情狀發生具有刑法重要性的變化時，基於實質正義的考量，應該要將個別的身體舉動切割觀察。

據此，本案是否應該將趙女的持榔頭敲擊與持刀刺殺行為分開檢驗，取決於在這兩個身體舉動之間，是否存在一個刑法上重要的事實變化。對於我們所關注的正當防衛問題而言¹⁸，本案的賈男持刀出言恫嚇，固然可能是一個現在不法侵害，但是賈男被攻擊而昏倒在地時，暫時沒有回復意識的可能性，表示先前的不法侵害可能就此結束。這個客觀事實的變更，使得趙女前後兩段的身體舉動是否係面臨現在不法侵害所為，有被分別檢驗的必要¹⁹，如果忽略這個客觀事實的變更，將產生未能持平評價其持刀刺殺行為的危險。因此，相較於第一、二審判決的整體評價模式，更審判決的切割評價模式是一個較能達成正確刑法評價的論述基礎。要提醒的是，此處的切割評價模式只是著眼於犯罪檢驗的合目的性，並不排除最終二個行為都成立犯罪，前後兩個行為在競合關係上卻構成行為單數，而成立法條競合或想像競合。

肆、防衛情狀

如前所述，趙女係面臨賈男持刀並言語恫嚇，故持榔頭敲擊賈男頭部，在賈男昏迷在地而短暫無法回復意識之下，又持刀刺死賈男。比較沒有疑義的是，如同更審判決所言，在賈男昏迷倒地的情況下，已經完全喪失攻擊趙女的能力，所以賈男臥倒在地的舉動，客觀上已經不可能對於趙女的利益形成侵害的危險，亦即沒有侵害可言。比較值得關注的是，賈男持刀並言語恫嚇的動作，是否已經構成現在不法侵害？

18 將趙女持榔頭敲擊頭部與持菜刀刺殺分開檢驗，對於趙女殺人故意的認定也有重要意義。趙女持菜刀刺殺頭部的行為，依其所持武器的殺傷力及攻擊致命部位來推論，較可能被認定有殺人故意，然而持榔頭敲擊頭部的行為，所持武器的殺傷力較弱，認定殺人故意的難度就比較高。無論如何，趙女在前後兩個行為時的主觀認知可能存在差異，有分別討論的必要。

19 正確注意此一區分者：高金桂（註17），頁122。

一、侵害概念

對此，姑且不論賈男持刀恫嚇的當時是否已經決意殺死趙女，從客觀第三者的角度來看，賈男所說的將「腦袋剝掉」本身就傳達出施加不法惡害的意思，持刀的動作也使相對人更嚴肅地相信未來施加不法惡害的可能性。因此，賈男的言詞恫嚇本身，已經使趙女心理安全感（個人法和平）喪失²⁰，其藉此強迫趙女放棄要求提供醫藥費，也同時侵害趙女的意思自由，與賈男後來有沒有真的把趙女的腦袋剝掉無關。問題是，對於心理安全感或意思自由的不法侵害，是防衛適格的侵害嗎？

多數學說認為，心理安全感及意思自由被公認是刑法所保護的法益，既然言詞恐嚇已經被相對人所知悉，在當下引發其心理不安或受迫，縱使恐嚇者根本還沒開始實現所預告的惡害，仍然可以被視為一種現在不法侵害²¹。不過，這個看法可能導致容許被害人殺死恐嚇者的結果²²。例如，行為人對不期而遇的仇敵恫嚇，下次又被他遇到就開槍射殺之。對於被恐嚇的人而言，由於他根本無法掌握何時又會與仇敵相遇，在絕大多數情況下也不可能請求警察機關提供無限期的人身保護，保全自己生命的最佳方式，就是在當場殺死恐嚇者，以終局地排除將來遇害的可能性。為了避免這種極端的

²⁰ 僅參考 *Thomas Fischer*, *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*, 58. Aufl., 2011, § 241 Rn. 2.

²¹ *Jürgen Baumann/Ulrich Weber/Wolfgang Mitsch*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 11. Aufl., 2003, § 17 Rn. 11; *Armin Engländer*, in: *Matt/Renzikowski* (Hrsg.), *Strafgesetzbuch Kommentar*, 2013, § 32 Rn. 12; *Thomas Rönau/Kristian Hohn*, in: *Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann* (Hrsg.), *Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar*, Band 2, 12. Aufl., 2006, § 32 Rn. 91 f.; *Antje Kroß*, *Notwehr gegen Schweigegelderpressung*, 2004, S. 82; *Knut Amelung*, *Das Problem der heimlichen Notwehr gegen die erpresserische Androhung kompromittierender Enthüllung*, GA 1982, S. 381 (385); *Petar Novoselec*, *Notwehr gegen Erpressung i. e. S. und Chantage*, NStZ 1997, S. 218 (219); *Matthias Eggert*, *Chantage—Ein Fall der Beschränkung des Notwehrrechts?*, NStZ 2001, S. 225 (226).

²² *Engländer* (Fn. 21), § 32 Rn. 33.

結果，文獻上便有主張，被恐嚇者所採取的防衛手段必須額外受到社會倫理的限制，亦即只能採取溝通性的反擊方式，或是紀錄對方的威脅行為（例如錄音、錄影），但不得私下殺死恐嚇者，否則大眾對於法秩序的信賴反而會受到動搖²³。

此一立場的問題在於，心理安全感及意思自由是刑法保護的個人利益，並不代表二者必定就是防衛適格的利益。儘管依照通說的定義，透過人類舉動而導致任何法律保護的利益可能受到侵害者，都構成防衛適格的「侵害」²⁴，在法條也未限制侵害法益的種類之下，似乎沒有理由將心理安全感及意思自由排除在外。然而，「侵害」的文義可以包含所有受法律保護的利益在內，不排除我們基於目的解釋，將對特定利益的侵害排除在「侵害」概念以外。事實上，通說也不是像上述定義一般，把所有侵害法益的行為都納入「侵害」的概念裡面。例如，通說就主張，難以歸屬於特定個人的公共秩序或善良風俗本身，專屬於國家警察的保護對象，為了避免個人動輒以警察自居反而動搖公共秩序，不屬於防衛適格的利益²⁵。除此之外，在個人法益之中，有些是無法強制實現的利益

²³ *Amelung* (Fn. 21), S. 398 ff.; *Walter Gropp*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 3. Aufl., 2005, § 6 Rn. 88; *Rönnau/Hohn* (Fn. 21), § 32 Rn. 92, 261; *Claus Roxin*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Band I, 4. Aufl., 2006, § 15 Rn. 102; *Rudolf Rengier*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., 2012, § 18 Rn. 93; *Fischer* (Fn. 20), § 32 Rn. 38.

²⁴ 例如 *Hans-Heinrich Jescheck/Thomas Weigend*, *Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil*, 5. Aufl., 1996, § 32 II 1. b.

²⁵ 僅參考 *Helmut Frister*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., 2009, § 16 Rn. 6; *Gropp* (Fn. 23), § 6 Rn. 69; *Bernd Heinrich*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 3. Aufl., 2012, Rn. 344. 有別於此，*Michael Köhler*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 1997, S. 266; *Georg Freund*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 2. Aufl., 2009, § 3 Rn. 96。主張超個人法益也具有防衛適格，只不過防衛權限取決於，相對於國家機關的執行職務，私人救助是否必要或合宜。張天一（註 16），頁 167-168 亦主張，通說在國家遭遇存亡危機時（例如，間諜竊取國家機密準備出境），也例外承認個人主張正當防衛的權利，而且國家與社會法益本質上可以轉化為個人利益，所以不宜將防衛適格的利益侷限在個人利益。本文認為，此一不同見解尚有值得斟酌之處。首先，正當防衛的功能在於，使個人於國家無法提供協助時仍能保全利益，而不是讓個人有權執行警察的任務。通說將正當防衛的保護對象限制在個人利益，

(例如：夫妻同居義務)，有些是僅能藉由國家限定的途徑來強制實現的利益（例如：債權），如果賦予個人最為銳利的正當防衛權，可能會架空法律僅提供弱度保護的意旨，所以也被排除在防衛適格的利益之外²⁶。由此可知，哪些法益具有防衛適格，必須綜合正當防衛的制度特徵及法律體系內部的其他規定來考量，沒辦法建立一個簡單的標準來決定，尤其不能簡單地以該法益是否受刑法保護來界定²⁷。因此，心理安全感及意思自由並非當然具有防衛適格。至少從通說在此時對防衛行為附加社會倫理限制也可以推知，通說也不認為心理安全感及意思自由值得受到百分之百的正當防衛權保護²⁸。

並不是完全否定個人保全公共利益的可能性，而是使個人只能在其他緊急權的界限內（緊急避難或現行犯逮捕）為之。因此，也有不少文獻主張，縱使國家最高利益受到不法侵害，公民依舊不能行使正當防衛權，至多行使緊急避難或德國基本法第 20 條第 4 項的抵抗權（僅參考 *Jescheck/Weigend* (Fn. 24), § 32 II 1. a)。其次，通說所理解的個人利益，其意義並不等於法益理論裡的「個人法益」，而是指他人的行為必須對於可得特定的個人利益造成威脅，所以縱使他人的不法行為性質上屬於侵害超個人法益的犯罪，只要同時造成可得特定的個人利益陷入急迫的危險，仍然是防衛適格的侵害（僅參考 *Jescheck/Weigend* (Fn. 24), § 32 II 1. a)；*Günter Stratenwerth/Lothar Kuhlen*, *Strafrecht Allgemeiner Teil I*, 6. Aufl., 2011, § 9 Rn. 66)。例如，醉態駕駛（刑法第 185 條之 3）雖然是超個人法益犯罪，但是只要在具體情況下，此一醉態駕駛可能追撞其他交通參與者，或是損及街道旁的商家財產，就屬於對個人利益的不法侵害，對此得行使正當防衛權。

²⁶ 參考 *Volker Erb*, in: *Joecks/Miebach* (Hrsg.), *Strafgesetzbuch Münchener Kommentar*, Band 1, 2. Aufl., 2011, § 32 Rn. 91; *Roxin* (Fn. 23), § 15 Rn. 32, 35; *Christian Jäger*, *Examens-Repetitorium Strafrecht Allgemeiner Teil*, 6. Aufl., 2013, Rn. 101 f.; *Urs Kindhäuser*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 5. Aufl., 2011, § 16 Rn. 12 ff.（以下簡稱 *Kindhäuser*, AT）；*Urs Kindhäuser*, *Strafgesetzbuch Lehr- und Praxiskommentar*, 4. Aufl., 2010, § 32 Rn. 14（以下簡稱 *Kindhäuser*, LPK-StGB）；*Volker Krey/Robert Esser*, *Deutsches Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., 2011, Rn. 475; *Kristian Kühl*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 7. Aufl., 2012, § 7 Rn. 35 ff.; *Rönnau/Hohn* (Fn. 21), § 32 Rn. 105; *Patrick Stemler*, *Die Notwehr*, ZJS 2010, S. 347 (348)；薛智仁，不法侵害之現在性與著手實行——最高院 99 台上 5562，台灣法學雜誌，182 期，頁 185-187（2011 年）。

²⁷ 通說見解，僅參考 *Günther Jakobs*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 2. Aufl., 1992, 12/3.

²⁸ 參考 *Roxin* (Fn. 23), § 15 Rn. 100.

有別於通說肯定恐嚇的侵害性質，只企圖在防衛手段上做進一步的限制，有少數文獻直接否定恐嚇的侵害性質。例如有學說指出，恐嚇只是一種以溝通的方式媒介的意思自由侵害，不是肢體性的法益侵害，所以不是防衛適格的侵害²⁹；類似於此，有認為此種對於意思自由的侵害，單純是間接透過被害人心理所造成的，正當防衛並非針對此種情形所量身訂作的³⁰。然而，這種說法最終並沒有解釋，為何只是因為利益侵害的途徑是溝通（動口），而不是肢體（動手）時，就不能對其施以正當防衛³¹。而且，如果貫徹此一想法，也會導致不合理的保護漏洞。詳言之，對於典型藉由言詞溝通來實施的不法侵害，例如詐欺取財、恐嚇取財、公然侮辱、誹謗等行為，這種限制等於使得整體財產及名譽利益完全不受正當防衛保護。對於生命、身體、自由等利益的不法侵害，這種限制則是不合理地依照侵害途徑，來決定系爭利益是否受正當防衛保護。舉例來說，在某甲的言語威脅底下，某乙被迫持刀刺殺某丙。依據這種見解，某乙透過肢體侵害某丙，某丙為保全自己生命而毆打某乙，其傷害行為構成正當防衛；然而，由於某甲透過言詞侵害某丙，某丙為保全自己生命而脅迫某甲阻止某乙，其強制行為不構成正當防衛。以正當防衛的意旨而言，不論是保護個人利益或是確保法秩序效力的角度，我們都無法說明，為何生命法益面臨肢體性的不法侵害時，值得以正當防衛來保護，而在面臨溝通性的不法侵害時，就變成不值得以正當防衛來保護。因此，少數說所提出的理由，也不足以否定心理安全感與意思自由的防衛適格。

本文認為比較值得贊成的看法是：承認心理安全感或意思自由

29 *Erb* (Fn. 26), § 32 Rn. 98.

30 參考 *Hennig Ernst Müller*, Zur Notwehr bei Schweigegelderpressung (Chantage), *NSiZ* 1993, S. 366 (368).

31 參考 *Rönnau/Hohn* (Fn. 21), § 32 Rn. 91; *Hennig Ernst Müller*, Notwehr gegen Drohungen, in: *Hoyer/Müller/Pawlik* (Hrsg.), *Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag*, 2006, S. 323 (334 f.).

具有防衛適格，就會架空侵害現在性的要求。詳言之，儘管正當防衛的功能在於讓公民無法及時受國家協助時，能夠有效地保護個人利益，但是它並非公民所享有的唯一緊急權限，其他諸如緊急避難（刑法第24條）、自助行為（民法第151條）、逮捕現行犯（刑事訴訟法第88條）等，也都具有賦予公民保護個人利益的功能。因此，在界定何時才能發動正當防衛權時，必須考量到正當防衛權在公民的緊急權限體系裡的特殊地位，避免其僭越其他緊急權限的適用範圍，使其他緊急權限較為嚴格的發動要件被架空³²。就此，相較於其他緊急權限對於緊急手段的模式或程度設有嚴格限制，正當防衛權的最大特色，正是其防衛手段不必受衡平性的限制，在必要的情況下，不法侵害者可能因為他人行使正當防衛權而死亡。因此，如果在不法侵害發生與否仍不明朗時，就承認其係現在不法侵害，如此銳利的正當防衛權所施加的對象，就很有可能是實際上並不打算從事不法侵害的無辜之人，此種風險分配將顯得不衡平。由此可知，通說認為只有在不法侵害已經立即而明顯時才具有現在性，正是為了確保防衛權行使的對象是真正即將實施不法侵害之人，只有這樣的人才必須忍受不受衡平性拘束的防衛後果³³。

32 特別強調這一點者：Dietrich Kratzsch, Der „Angriff“ – ein Schlüsselbegriff des Notwehrrechts. Zugleich eine Besprechung des Urteils BayObLG v. 9. 1. 1985 – R Reg 5 St 272/84, StV 1987, S. 224 ff.

33 Vgl. Frister (Fn. 25), § 16 Rn. 15; Freund (Fn. 25), § 3 Rn. 101; Köhler (Fn. 25), S. 266; Stratenwerth/Kuhlen (Fn. 25), § 9 Rn. 69. Jakobs (Fn. 27), 12/22 另外主張，計畫性的防範犯罪及取回被犯人剝奪的利益，基本上屬於警察的任務，只有在不法侵害立即存在時，個案的強迫性才會高出我們對權限分配的顧慮。贊同此見解者：王皇玉，竊盜被害人之贓物追回權與正當防衛——評最高法院九十一年度台上字第四〇〇三號判決，月旦法學雜誌，107期，頁236（2004年）；王皇玉，正當防衛的始點，月旦法學教室，105期，頁28（2011年）（未來犯罪之預防屬於國家任務）。Marc André Wiegand/Benno Zabel, Zur Notwendigkeit der Präzisierung des Merkmals der „Gegenwärtigkeit“ des Angriffs im Rahmen der Dogmatik zu § 32 Abs. 2 StGB, HRRS 2004, S. 202 (209, 211) 將不法侵害理解為侵害者透過其行為表現出對於法關係客觀效力的置疑，以侵害者「對他人法地位的不尊重直接表現在行為實施之中」來理解侵害現在性概念，認為通說對現在性的定義，同樣是在強調現在性概念具有使侵害行為客觀明確化的功能。

然而，在恐嚇個人（刑法第305條）的案件裡，被害人當下產生的恐懼，通常不是因為他方所實施的不法侵害已經立即而明顯，而是單純因為將來被施加不法惡害的預期心理，這種心理壓力的有無、程度及延續時間，與其所預期的不法惡害在客觀上的急迫性沒有必然的關連。事實上，恐嚇者通知不法惡害時，也不確定他方是否會屈從自己的意思，對於屆時是否以及何時要施加不法惡害，未必已形成明確的想法³⁴。例如，雖然行為人向被害人宣稱，下次不期而遇時就要開槍射殺之，但是恐怕連行為人都不知道，究竟何時才會再與被害人相遇，果真相遇的時候是否仍然維持相同的心意，我們甚至可以想像，行為人正是為了避免再次相遇才出言恐嚇，希望被害人自行躲避，自始沒有開槍射殺被害人的計畫。因此，如果不能確定恐嚇者是否或何時會施加不法惡害，就逕自以其係對於「個人安全感」之現在侵害，使被害人能立刻採取銳利的防衛手段，以終局排除行為人未來施加不法惡害的可能性，等同於承認被侵害者對於不法侵害的恐懼就足以創設正當防衛的權限。很顯然地，這恰好與嚴格限縮侵害「現在性」的出發點背道而馳³⁵。為了避免此一後果，必須自始將恐嚇行為排除在侵害概念以外。

上述基本觀念，同樣適用在具有不法強制性質的脅迫行為。例如，某甲警告某乙再不償還欠款，就向警方告發其販賣海洛因的犯行，某乙因此籌錢還債。按照通說，某甲通知的惡害內容合法（告發犯罪），所欲達成的目的也合法（行使債權），但是二者之間欠缺所謂內在關連性，所以其脅迫行為構成強制罪（刑法第304條）³⁶。此時，在某乙清償債務之前，某甲可能告發他犯罪一事就有如一把

34 依據通說的定義，恐嚇行為係指對他人預告將來的不法惡害，只要依其客觀內涵足以使他方相信其能夠支配惡害的實現即可，僅參考 *Fischer* (Fn. 20), § 241 Rn. 3.

35 參考 *Müller* (Fn. 31), S. 335; *Frister* (Fn. 25), § 16 Rn. 14, 16 f; *Jakobs* (Fn. 27), 12/27 (Fn. 49).

36 僅參考 *Fischer* (Fn. 20), § 240 Rn. 50.

劍架在脖子上，某乙的意思自由受到不法限制，而且會持續到脅迫行為結束之後。不過，此一心理強制狀態一樣是來自某乙擔心某甲預告的惡害可能實現，對於這個合法惡害可能實現的風險，某乙既然不能行使緊急避難權加以迴避³⁷，依舉輕以明重的原則，更不能行使更銳利的正當防衛權迴避。從這個觀點來看，如果我們承認某乙的意思自由處於現在不法侵害，等於是承認個人現時對於未來實現合法惡害的恐懼本身，就可以為他創設正當防衛權，阻止其原本必須承受的合法惡害的實現，此一結果已經遠超出正當防衛的功能範圍。因此，具有不法強制性質的脅迫行為，也應該被排除在侵害概念之外。

基於上述，恐嚇行為儘管不法侵害他人的心理安全感或意思自由，但是不構成防衛適格的侵害。在這類的案件裡，對於恐嚇者所預告的不法侵害，被害人能否以及使用何種緊急權限來避免，必須以所預告的不法侵害行為本身的迫切性為判斷基準。如果在恐嚇的當時，恐嚇者所預告的不法侵害已經立即而明顯（例如：不交保護費就馬上砸店），符合正當防衛的現在性標準，被害人當下就可以對其行使正當防衛權；如果恐嚇者所預告的不法侵害，必須等待一段時間之後才會發生（例如：三天內不清償債務就放火燒屋），此時尚不符合正當防衛的現在性標準，僅能在緊急避難的界限之內防禦不法侵害，尤其是要採取迴避的措施，或者尋求可能的國家救助管道³⁸。如果恐嚇者所預告的不法侵害，也不符合緊急危難的要件（例如：三天內不清償債務就施法讓厄運降臨），被害人就無權對恐嚇者採取任何緊急權限。簡言之，依據恐嚇被害人所遭遇的不法侵害急迫性，而賦予其不同程度的緊急權限，才可以平衡地兼顧恐嚇者與被恐嚇者的利益，也不用如同通說一般，一方面賦予正當防衛

³⁷ 參考 *Roxin* (Fn. 23), § 16 Rn. 54.

³⁸ *Kratzsch* (Fn. 32), S. 229; *Müller* (Fn. 31), S. 336-337; *Frister* (Fn. 25), § 16 Rn. 15, 17.

權，另一方面卻訴諸標準模糊的社會倫理限制，限制只能採取溝通性的防衛手段³⁹。

回到本案，賈男持刀恫嚇趙女作為一種對於心理安全感及意思自由的不法侵害，不是防衛適格的侵害。趙女對賈男有無正當防衛權的關鍵在於，賈男所預告的殺人行為在當下是否已經構成現在不法侵害。就此而言，本案各審判決在防衛情狀的認定上，均著眼於趙女是否面臨生命的現在不法侵害，是一個正確的方向。可惜的是，本案各審判決似乎沒有意識到，賈男持刀恫嚇是否基於對心理安全感及意思自由的不法侵害，而構成現在不法侵害，以致於錯失了探討上述爭議問題的機會。

二、侵害現在性概念

關於賈男的恐嚇是否構成對趙女生命的現在不法侵害，本案第一、二審判決以賈男構成預備殺人罪、並斟酌趙女的受虐婦女經驗為由而肯定之。在最高法院認為現在不法侵害以賈男已著手殺人為前提之後，更審判決不再強調賈男的行為階段及趙女的特殊經驗，而是逕行就個案情狀，依據一般社會通念肯定趙女的生命已面臨現在不法侵害。儘管各審判決的結論相同，但是所持的侵害現在性標準明顯不同，我們有必要先確定，侵害現在性標準有無必要連結不法侵害的犯罪階段，再反省第一、二審判決所援引的受虐婦女經驗觀點，是否應該構成侵害現在性判斷的因素之一，最後再就本案表達本文的看法。

(一) 侵害現在性的判斷標準

通說主張，現在不法侵害係指侵害直接即將開始、業已發生或

39 深入批評：Johannes Kaspar, Gewaltsame Verteidigung gegen den Erpresser? Zu den Grenzen der Notwehr in den Fällen der sogenannten „Chantage“, GA 2007, S. 36 (37-42).

尚在持續中⁴⁰。從定義的文字敘述可以瞭解，通說試圖透過所謂「直接即將開始」來劃分未來與現在的侵害，透過所謂「尚在持續中」來劃分現在與過去的侵害。不過，比起「現在」的概念本身，這些文字描述其實並沒有具體化的效果。例如，一個埋伏在被害人家門外準備進行綁架的人，其埋伏行為已經是直接即將開始的不法侵害嗎？結論會因為我們所持的觀察角度而有所不同。從行為人已經在進行其綁架計畫來說，埋伏行為不是即將開始的不法侵害，而是業已發生的不法侵害；但是，如果從行為人真正支配人質來說，行為人至少必須等待被害人現身，才有支配人質的機會，埋伏稱不上是直接即將開始的不法侵害。在現在性的判斷上應該以進行綁架計畫作為比較基準，還是以真正支配人質作為比較基準，這個定義顯然沒有任何進一步的線索，以致於在個案判斷時，經常只能淪為說文解字。

1. 援引犯罪階段理論

為了避免上述困境，通說往往援引刑法的犯罪階段理論，嘗試將現在性的標準具體化。例如，關於何謂「直接即將開始」的侵害，不少學說主張可以適用或類推適用犯罪的著手標準⁴¹，也有認為不受著手標準的限制，將與著手實行密接的最後預備階段納入現在侵害的範疇⁴²。本案第一、二審判決以賈男的行為構成預備殺人罪而肯定現在不法侵害的存在，最高法院以其行為尚未達著手殺人而質疑二審判決的認定，儘管彼此見解不同，其援引犯罪階段理論來認定侵害現在性，則是明顯一致。至於何時是「尚在持續中」的侵害，多數學說也是傾向援引犯罪階段理論，認為在犯罪實質上終

40 Harro Otto, Grundkurs Strafrecht: Allgemeine Strafrechtslehre, 7. Aufl., 2004, § 8 Rn. 31.

41 Jakobs (Fn. 27), 12/23; Kühl (Fn. 26), § 7 Rn. 40; Engländer (Fn. 21), § 32 Rn. 14; Dominik Ludwig, „Gegenwärtiger Angriff“, „drohende“ und „gegenwärtige Gefahr“ im Notwehr- und Notstandsrecht, 1991, S. 101-103.

42 Roxin (Fn. 23), § 15 Rn. 24; Krey/Esser (Fn. 26), Rn. 486.

了之前，尤其在屬於繼續犯類型的侵入住宅或剝奪行動自由的行為，在行為人離開住宅或釋放被害人之前，仍然屬於現在不法侵害⁴³。問題是，犯罪階段理論的功能是否與界定侵害現在性的功能相同，所以前者有助於後者的具體化呢？

按，犯罪階段理論將刑事不法行為區分為決意、(陰謀)、預備、著手、既遂及終了等階段，其主要目的在於依行為距離法益侵害的遠近，彰顯各個犯罪階段的應刑罰性不同。基於行為刑法原則，行為人單純具有犯罪決意固然不罰，但是針對後續實踐犯罪決意的行為，立法者得以犯罪階段為時間座標來劃定可罰性的範圍，亦即原則上僅處罰既遂行為，例外始處罰未遂行為，處罰預備及陰謀行為則是極端例外。為了將未遂、預備或陰謀行為納入處罰，必須特別明文規定，始符合罪刑法定原則⁴⁴。基於刑罰的最後手段性，一個行為何時已進入未遂(著手實行)階段，所考量的是系爭行為所展現的法益危險性或法敵對意志，是否已經達到需要動用刑罰來預防的程度，在行為人尚未對法益侵害的實現失控之前，就不宜認定為著手實行，而預備行為之認定更是要極其嚴格。

由此觀之，通說援引犯罪階段理論作為認定侵害現在性的標準或參考，明顯忽略其與正當防衛的指導精神不符。按，正當防衛並不是在賦予個人施加刑罰的權限，而是在國家無法及時阻止利益侵害時，承認個人自我保護的可能性。因此，在劃定正當防衛界限時所要考慮的因素，不是國家動用刑罰手段保護法益的必要性，而是在急迫狀況之下，如何一方面提供被侵害者有效防衛的機會，另一方面又不至於過度動搖國家武力獨占的地位。基於這樣的想法，什麼利益適合以正當防衛來保護，與該利益是否以及在多大範圍內受

43 Otto (Fn. 40), § 8 Rn. 34; Roxin (Fn. 23), § 15 Rn. 28; Baumann/Weber/Mitsch (Fn. 21), § 17 Rn. 16.

44 Thomas Hillenkamp, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Erster Band, 12. Aufl., 2007, Vor § 22 Rn. 2.

到刑法保護，沒有必然的關連，個人得以實施正當防衛的對象，不應限制在構成刑事不法的行為上，而是包括行政及民事不法行為在內⁴⁵。同時，何時不法侵害進入現在階段，也不是考量國家是否有必要動用刑罰來處罰該侵害者，而是考量被害者能否有效地保護自己或他人的利益，又不至於使侵害者承受過大的風險。我們不能為了盡早地預防犯罪的發生，而將現在不法侵害的射程無限往未來延伸，也不能為了事後懲罰已經發生的犯罪，而將現在不法侵害的射程無限往過去回溯。因此，通說援引犯罪階段理論來界定不法侵害的現在性，不但忽視其適用範圍不及於行政與民事不法的行為⁴⁶，也忽視其標準無法滿足劃定有效防衛之必要界限的功能。

由於基本思考的落差，著手或預備的標準是否確實有助於將不法侵害的現在性標準具體化，恐怕也值得懷疑。首先，不法侵害之現在性標準，係以客觀上具有侵害傾向的行為為判斷基礎，重點在於被害利益即將喪失，而通說的著手實行標準，則是以行為人犯罪計畫或其所設想的事實作為判斷基礎，被害利益是否即將喪失亦不重要，所以二者自始就因為判斷基礎不同而無法相互援用⁴⁷。例如，行為人持短刀把玩時，手滑而不小心使短刀射向他人，由於行為人始終欠缺殺人計畫，所以此一行為無法被認定為著手殺人，但是過失任由短刀射向他人，無疑是現在的不法侵害。如果主張不法侵害之現在性判斷應適用或類推適用著手標準，將會使生命受到過失行為威脅的人，自始被排除在正當防衛的保護範圍之外。其次，不論是將預備行為視作現在不法侵害，或是將預備的最後階段視為現在不法侵害，如果能夠有助於侵害現在性標準的具體化，前提必須是預備行為的概念有具體的輪廓。然而，究竟何時算是預備行為

45 薛智仁（註 26），頁 186。不同見解：柯耀程，正當防衛界線之認定，月旦法學雜誌，60 期，頁 87（2000 年）。

46 相同見解：Rönnau/Hohn (Fn. 21), § 32 Rn. 144.

47 相同見解：Erb (Fn. 26), § 32 Rn. 107.

的起點，基本上也是一個學說有意忽略或甚至無解的問題⁴⁸，以致於侵害現在性的界限也會隨著模糊的預備概念而浮動。所以，援引預備概念作為侵害現在性的標準，似乎也只有文字替換的效果⁴⁹。

據此，通說不同程度地援引著手與預備概念嘗試將現在性標準具體化，不符合正當防衛的基本理念，其具體化的成效也相當可疑。不論是本案第一、二審的預備標準，或是最高法院的著手標準，都不適合用來判斷侵害現在性。比較根本的作法，應該是依據正當防衛的制度目的，來推論侵害現在性的判斷標準。

2. 最後有效防衛時間點

正當防衛之目的在於使私人能夠有效防衛自己或他人的利益，因此有少數學說採取所謂有效理論（Effizienzlösung），只要他人準備實施的不法侵害，已達到最後有效防衛的時間點，此一不法侵害即已進入現在的階段⁵⁰。類似於此，亦有認為對於將來才會發生的不法侵害，如果錯過現在就無法有效防衛，或只能採取更嚴重的方法來防衛，屬於正當防衛的類似情狀（notwehrähnliche Lage），得類推適用正當防衛的規定⁵¹。這兩種觀點，都是著眼於確保受侵害者的有效防衛機會，使正當防衛在某程度上擴及未來的不法侵害（所謂預防性正當防衛）⁵²。有別於此，通說認為，現在不法侵害

48 黃榮堅，基礎刑法學（下），4版，頁478-479（2012年）。

49 類似質疑：Rönnau/Hohn (Fn. 21), § 32 Rn. 146.

50 Eberhard Schmidhäuser, Strafrecht Allgemeiner Teil: Lehrbuch, 2. Aufl., 1975, 9/94; Eberhard Schmidhäuser, Strafrecht Allgemeiner Teil: Studienbuch, 2. Aufl., 1984, 6/61; 黃榮堅（註4），頁93-95；黃榮堅，基礎刑法學（上），4版，頁231-232（2012年）；黃惠婷，正當防衛之現在不法侵害，台灣本土法學雜誌，23期，頁138（2001年）。

51 Hartmut Suppert, Studien zur Notwehr und „notwehrähnlichen Lage“, 1973, S. 404.

52 本文使用「未來不法侵害」及「預防性正當防衛」（Präventive Notwehr）用語，純粹是出於行文便利的考量，有必要稍微說明其意義以避免不必要的誤會。基本上，正當防衛的主要功能在於保護個人利益，而不是在處罰不法侵害者，如果不法侵害已經導致個人利益終局喪失，就沒有承認正當防衛權的餘地。因此，從個人利益終局喪失的角度來看，條文所稱的「現在不法侵害」，

應以侵害立即而明顯為標準，而不是以被害人最容易或最有效防衛為標準，所以對於未來的不法侵害，沒有行使正當防衛權的餘地，只能在緊急避難的尺度之內防止不法侵害。

此種著重確保有效防衛可能性的侵害現在性標準，在家暴案件裡尤其具有意義。因為，在這類案件中，施虐者可能習於對其他家庭成員反覆施加暴行，或者家庭成員彼此關係持續緊張，導致彼此處於隨時可能爆發衝突的狀態。在這種狀態下，那些身材體力較柔弱的受虐婦女或孩童，可以預期會再次受到施虐者的不法侵害，但是如果等到施虐者的不法侵害再度來臨時，又因為實力的落差根本無從有效防衛，所以多半只能利用施虐者正在睡覺或尚未打算施暴的時機，也就是在施虐者的不法侵害尚屬未來時，先行採取防止不法侵害發生的措施。舉例來說⁵³，（例一）某甲經常在喝醉後動輒對妻小拳打腳踢，某次喝醉的某甲不滿妻子某乙干擾他休息，再度施以拳腳，害怕被某甲毆打的三個小孩只敢躲在一旁。某甲打完某乙與小孩某丙之後，轉身要打另一個小孩某丁時，某丁就先持平底鍋敲擊父親的頭部。對某丁來說，雖然某甲還沒真的動手毆打，但是依先前家暴的經驗，如果不先行反制就難逃被毆打的命運。更極端的情況是，（例二）某甲在毆打妻兒之後上床睡覺，某丁乾脆持平底鍋殺死沈睡的某甲，以徹底結束母親與兄弟的痛苦。如果必須等某甲醒過來，恐怕很難阻止他再度對母親或自己施暴。在這兩個家暴事件，採取有效理論或承認正當防衛類似情狀，都傾向於肯定某丁的行為構成正當防衛。

本質上必定是未來才會使個人利益終局喪失的不法侵害，其所使用的「現在」概念，只是在表達那些時間上比較接近個人利益終局喪失的未來侵害行為，排除那些時間上比較遠離個人利益終局侵害的未來侵害行為，而後者即是本文所稱的「未來不法侵害」，以便與條文所稱的「現在不法侵害」概念作對照。學說上所使用的「預防性正當防衛」用語，同樣是用來指稱針對「未來不法侵害」的防衛手段，以與針對「現在不法侵害」的防衛行為做對照。當然我們必須承認，這些用語都容易引人誤解，所以應該盡量避免使用。

⁵³ 以下兩個案例參考 *Otto* (Fn. 40), § 8 Rn. 39, 40.

依據我們前面對於侵害現在性所闡釋的觀念，正當防衛的功能是使受到不法侵害的個人得以有效保全利益，所以現在性的判斷結果，不應該重大減損個人有效保全利益的可能性。但是另一方面，正當防衛作為一個最銳利的緊急權限，必須有充分證據顯示防衛對象正是不法侵害的人，才能使其承擔不受衡平性拘束的防衛行為後果。在這個想法底下，侵害現在性的個案判斷結果，必定是權衡有效防衛與降低誤判風險的產物。以例一而言，一方面可以確定，某甲處於伸手就能毆打某丁的位置，一旦真的動手，某丁極可能無從防衛，所以必須在某甲尚未動手之前，就肯定存在現在不法侵害。另一方面，在某甲已經轉身面向某丁的時候，依照他向來的行為模式，已幾近確定有接著毆打某丁的意思，此時肯定現在不法侵害存在，不致於使某甲承擔過大的誤認風險。由此可知，縱使依據通說的現在性標準，此時某丁也已經面臨現在不法侵害，沒有採取有效理論或承認正當防衛類似情狀的必要。就例二而言，儘管某甲不會因為睡覺而改變其施加暴行的傾向，但是某甲也不是在睡醒之後就會自動立刻施加暴行，我們無法在他睡覺時就充分肯定，之後是否以及何時會發生觸發某甲施暴的事件。從有效保全利益的需求來說，沈睡的某甲是否以及何時會再度施加暴行尚屬未定之天，其他家庭成員尚未面臨明顯而立即的人身傷害危險，存在尋求其他救助管道的空間。從避免誤判風險來說，縱使某甲對於妻兒來說有如一枚不定時炸彈，我們仍然必須承認，某甲畢竟不是一枚完全只受自然法則支配的炸彈，而是一個具有自主決定能力的人，他在每一個時間點都可以重新考量，是不是實施不法侵害，只要沒有客觀證據顯示他將會再度做出不法侵害的決定，我們就必須將他視為一個舉止合法的個人，只基於其公民身分承擔最低限度的連帶義務，而不是令其承擔不受衡平性拘束的防衛行為後果。依此，如果我們只知道，某甲在睡醒之後很可能會再度施加暴行，但是不確定是何時會施暴，以致於必須在他睡覺時採取必要的保護措施（所謂最後有效防衛時點），這只能構成緊急避難意義下的「緊急危難」，某丁的防

止措施應該遵守緊急避難的尺度⁵⁴。就此而言，有效理論及承認正當防衛類似情狀的觀點，脫離現在不法侵害必須明顯而立即的拘束，使正當防衛權擴大適用於不確定何時會實現的持續危險（Dauergefahr）情狀，使被視為危險源的個人承擔過大的風險⁵⁵。

對於例二的某丁只能行使緊急避難權的結果，學說上批評這是對被害人法益保護的打折扣，使侵害者永遠立於不敗之地，無異於刑法對不法侵害行為的鼓勵⁵⁶。這個批評忽略了，正當防衛是個人在利益侵害終局發生之前就被賦予的緊急權限，當我們在此時稱呼其中一方是「不法侵害者」的時候，其精確的意思是，這個人被預測下一步將會採取不法侵害的行為，而不是他真的已經採取不法侵害的行為；相對應地，當我們稱呼另一方是「被害人」的時候，是指他被預測下一步即將遭受不法侵害，而不是指他的利益已經真正

54 參考 *Erb* (Fn. 26), § 32 Rn. 105; *Fischer* (Fn. 20), § 32 Rn. 19; *Frister* (Fn. 25), § 16 Rn. 15, § 17 Rn. 5, 24; *Gropp* (Fn. 23), § 6 Rn. 77; *Heinrich* (Fn. 25), Rn. 346; *Thomas Hillenkamp*, In tyrannos-viktimologische Bemerkungen zur Tötung des Familientyrannen, in: Kühne (Hrsg.), Festschrift für Koichi Miyazawa, 1995, S. 141 (154); *Kindhäuser*, AT (Fn. 26), § 16 Rn. 20; *Köhler* (Fn. 25), S. 267; *Kühl* (Fn. 26), § 7 Rn. 42; *Roxin* (Fn. 23), § 16 Rn. 21; *Jescheck/Weigend* (Fn. 24), § 33 IV 3 a; *Baumann/Weber/Mitsch* (Fn. 21), § 17 Rn. 11; *Uwe Murmann*, Grundkurs Strafrecht, 2011, § 25 Rn. 81; *Otto* (Fn. 40), § 8 Rn. 168; *Kratzsch* (Fn. 32), S. 225; *Ludwig* (Fn. 41), S. 115; *Edward Schramm*, Ehe und Familie im Strafrecht, 2011, S. 146 f.; *Stemler* (Fn. 26), S. 349; *Stratenwerth/Kuhlen* (Fn. 25), § 9 Rn. 69; *Johannes Wessels/Werner Beulke*, Strafrecht Allgemeiner Teil, 42. Aufl., 2012, Rn. 329; *Joachim Renzikowski*, Notstand und Notwehr, 1994, S. 289.

55 *Roxin* (Fn. 23), § 15 Rn. 23 另外批評，一個計畫中或預備中的侵害，不僅不是現在侵害，而是在概念上根本不構成侵害。如果如此銳利的正當防衛權，可以廣泛地用在預防侵害，可能與社會的和平秩序及國家武力獨占相抵觸。本文對此批評持保留立場。首先，一個預備中的侵害在概念上是否構成侵害，取決於正當防衛的制度目的，並非當然就不構成侵害。尤其在某些情況下，預備的侵害本身就使他人有立即採取防衛手段的必要性，甚至立法者也已經將預備行為納入處罰，不論從保護個人利益或是證明法秩序效力的角度來說，都無法自始將其排除在侵害概念之外。其次，正當防衛權自始就有預防犯罪的性質，而且是突破國家武力獨占的機制，所以重點不在於正當防衛可能與國家武力獨占原則相抵觸，重點僅在於，正當防衛所容許的時間範圍有多大，才是可被接受的國家武力獨占原則的例外。因此，上述批評至少不是切中核心的論點。

56 黃榮堅（註4），頁95。

被害。因此，在界定正當防衛權的適用範圍時，其發動條件是建立在對於未來事件發展的預測之上，不論我們所做的客觀預測多麼合理，它永遠都存在與實際事件發展不同的可能性，我們所界定的「現在不法侵害」，必須能夠確保，縱使所要預防的不法侵害結果沒有真正實現，不受衡平性拘束的防衛行為對無辜之人所造成的後果，仍然可以被視為一個容許風險的後果。就此而言，什麼樣的現在性標準值得被接受，重點不在於其導致被害人保護利益的空間變大或變小，重點在於其所呈現的雙方風險分配合理或不合理。對於一個還沒有充分客觀事實足以確定即將發生的不法侵害行為，潛在被害人僅得行使緊急避難權，並不是無理地縮小其保護利益的空間，而是平衡兼顧潛在不法侵害者的合法利益所致，亦即是合理分配衝突雙方風險的結果。

當然，學說上對於某丁只能行使緊急避難權的批評，其根本的意思就是在強調，這種風險分配正是過於有利不法侵害者而不利被害者。然而，本文認為尚有斟酌餘地。第一個理由是，潛在不法侵害者的利益保護需求並未顯著降低。我們固然可以說，一個已經被證實即將採取不法侵害行為的人，原本只要放棄侵害行為，就能夠保全自己的利益不會因為被害人的反擊而喪失，既然他仍然決定要從事不法侵害，某程度上就要承擔利益喪失的後果。對於有如自陷風險般的不法侵害之人，法律保護其利益的需求比較低，令其承擔不受衡平性拘束的防衛行為後果，仍屬合理。但是，尚未被證實即將採取不法侵害行為的人，只是被預測有從事不法侵害的傾向，對於這種尚無具體不法侵害的決意，或是尚未將不法侵害的決意付諸實行的人，我們沒有理由認為，他在這個時候就已經可以預期他人的反擊而承受利益的損失，以致於法律保護其利益的需求大幅降低。如果以對照的方式來表達，此種潛在不法侵害者的利益地位，仍然高於已被證實的不法侵害者，但是可能低於與不法侵害完全無關的第三人。因此，使被害人的防衛行為受到緊急避難尺度的限

制，比較能符合潛在不法侵害者的保護需求。另一個理由是，緊急避難也不至於過度侷限被害人保護利益的可能性。因為，此時被害人的緊急避難權，係針對應對危難來源負責的未來不法侵害者，性質上是防禦性緊急避難（*Defensivnotstand*）。防禦性緊急避難的容許性，固然是取決於避難行為保全利益與犧牲利益之間的衡平性，不過有鑑於避難對象自己必須為危難的形成負責，其利益衡量的標準，並不是保全利益顯然優越於犧牲利益，而是只要犧牲利益不顯然優越於保全利益即可。換言之，只有在犧牲利益明顯大於保全利益時，被害人才必須捨棄必要的避難行為。依此，家暴受虐者為了防止生命或身體的危險而殺死施暴者，如果是個案裡的最後手段，仍然可能基於防禦性緊急避難而阻卻違法性⁵⁷。

綜上所述，本文不贊成以有效理論來界定侵害現在性的界限，也不贊成正當防衛類似情狀的概念，兩種觀點均片面強調被害人有效保護利益的可能性，忽略侵害現在性之界定必須平衡地考量不法侵害者所承擔的風險。對於未來不法侵害的防禦手段，只能適用緊急避難來阻卻違法。

3. 危險急迫性之具體判斷

至此可知，侵害現在性的判斷標準，無法藉由犯罪階段理論具體化，也不能以最後有效防衛時間點來取代，究竟何時算是侵害直接即將發生，只能綜合客觀情狀認定，特定法益是否面臨具體危險，該行為可以直接導致侵害出現，尤其要考量，如果不採取反擊措施，侵害行為所開啟的因果流程將有何種後果。通說對於侵害現在性的定義只能停留在「即將開始」的抽象公式層次，是因為它根

⁵⁷ *Frister* (Fn. 25), § 17 Rn. 28 f.; *Jakobs* (Fn. 27), 13/46; *Hans-Ludwig Günther*, *Defensivnotstand und Tötungsunrecht*, in: Böse/Sternberg-Lieben (Hrsg.), *Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrechts: Festschrift für Knut Amelung zum 70. Geburtstag*, 2009, S. 147 (153 ff.).

本上就不是一個放諸四海皆準的共通標準，永遠只能委諸個案情狀做綜合判斷。

基此，本案的更審判決不再拘泥於賈男持刀恐嚇是否為預備或著手殺人，直接就趙女先前與賈男之激烈衝突、案發當時賈男持刀威嚇已顯示其有強烈殺意、案發現場空間狹小，趙女生命顯係處於賈男控制範圍之內等客觀情狀，認定賈男確實危及趙女之生命安全，是一個正確的判斷模式。不過，其推論趙女生命陷入急迫危險的關鍵因素，亦即賈男持刀威脅已有強烈殺意一事，則是一個欠缺充分事實基礎的論斷⁵⁸。因為，如果不考量趙女個人的認知，從持刀並言詞恫嚇「把腦袋剝掉」的舉動本身，我們只能百分之百肯定這是一個恐嚇行為，但是關於賈男持刀是為了踐行殺人決意所作的準備動作，還是搭配言語來強化其恐嚇效力而已，就沒辦法從這個舉動明確地推論得知。由於賈男已經死亡，無法取得其陳述來證明有無殺人決意，在只能倚賴趙女的單方陳述來建構整個事件經過的情況下，上述兩種可能性都無法被排除，於是產生了一個問題：在不確定賈男有殺人決意的情況下，這算是趙女生命面臨直接危險的狀況嗎？

從現在不法侵害的定義來看，這個問題涉及其所預設的危險概念為何⁵⁹。如果以抽象危險概念為基礎，只要依據一般經驗判斷該行為接下來會演變成侵害，不必證明該行為已對個別保護客體造成危險，就可以肯定其侵害現在性。依此，以更審判決所指出的客觀情狀，就算無法確定賈男已有殺人決意，如果當時的衝突對峙持續下去，可能導致賈男揮刀殺趙女，是一個合乎一般經驗的判斷。然

58 同樣質疑本案的事實不明：李佳玟發言，賴芳玉主持，「從家暴受虐婦女正當防衛殺人案探討受虐婦女經驗及女性主義法學於司法實踐之可能性」座談會紀錄，全國律師，12卷2期，頁71-74（2008年）；高金桂（註17），頁120；林孟皇（註13），頁56。

59 Kratzsch (Fn. 32), S. 226 f.

而，如果以具體危險概念為基礎，就必須證明該行為已經對個別保護客體造成危險，才能肯定其構成現在性侵害。依此，更審判決所指出的客觀情狀無法推論出賈男有殺人決意，如果賈男沒有其他使殺人決意客觀化的舉動（例如舉刀揮擊、逐步逼近趙女），當時的對峙場面並未使趙女的生命陷入危險狀態。若是承審法院仍然懷疑賈男有殺人決意，就只能適用**罪疑唯輕原則**，假定趙女的生命已面臨賈男的現在不法侵害⁶⁰。

基於侵害現在性標準的管控風險性質，本文贊同以具體危險概念為基礎⁶¹。如果以抽象危險概念為基礎，潛在被害人在不確定是否會遭到不法侵害的狀況下，比較勇於採取防衛措施。然而，其同時大幅提高的風險是，被誤認為不法侵害者的第三人，也要承擔不受衡平性拘束的防衛後果。我們都知道，防衛行為只能對不法侵害者為之，不能對不法侵害者以外的第三人為之，正是因為只有前者才是導致他人利益陷入危險的人，他必須自行承擔被害者防衛的風險，如果可以將此風險轉嫁給無辜第三人來承擔，是對第三人不公平的風險分配。因此，使無辜第三人被誤認為不法侵害者的機會大增，牴觸上述不法侵害者與無辜第三人的風險分配⁶²。相較之下，以具體危險概念為基礎，就會使侵害現在性的判斷必須以更多客觀事證為基礎，只有在確定存在一個直接危及他人利益的具體不法行為時，潛在被害人才能行使正當防衛權，降低由無辜第三人承擔防衛後果的風險。至於潛在被害人可能在情況緊迫之下，誤以為存在造成自己或他人法益具體危險的不法侵害，只能透過容許構成要件錯誤來解決。

60 罪疑唯輕原則在阻卻違法事由不明時之適用，參考 *Friedrich-Christian Schroeder/Torsten Verrel*, *Strafprozessrecht*, 5. Aufl., 2011, Rn. 283; *Engländer* (Fn. 21), § 32 Rn. 65.

61 結論相同：Kindhäuser, AT (Fn. 26), § 16 Rn. 18; Kindhäuser, LPK-StGB (Fn. 26), § 32 Rn. 17.

62 參考 Kratzsch (Fn. 32), S. 226 f.

據此，侵害現在性以特定利益已陷入具體危險為必要。本案既然無法證明賈男持刀係出於殺人決意，就無法肯定其行為已對趙女生命造成具體危險，但也無法排除賈男持刀係出於殺人決意，所以也無法排除其行為已對趙女生命造成具體危險。此時，事實審法院在訴訟上的正確作法，應該適用罪疑唯輕原則，假定該行為已造成趙女生命的具體危險，肯定現在不法侵害的存在⁶³。

(二) 考量受虐婦女的特殊經驗

1. 對本案的真正意義

至此可知，縱使依據通說的侵害現在性定義，基於罪疑唯輕原則之適用，就可以肯定本案的趙女生命面臨賈男的現在不法侵害，不必如同本案的第一、二審判決，進一步突破傳統實務及學說，一併援引受虐婦女的特殊心理經驗來認定侵害現在性。然而，為什麼這兩個判決以本案為契機，引進考量受虐婦女特殊經驗的觀點呢？除了法院可喜地開始有性別意識之外，在訴訟上更重要的可能理由是，本案第一、二審法院其實也意識到，賈男在當時究竟有無殺人決意，是一個無從確認的事實問題。因此，賈男構成預備殺人罪的評價已純屬假設，如果要進一步肯定趙女的生命面臨現在不法侵害，必須援引一個「客觀」的心理學根據作為支持：趙女有受虐婦女之創傷症候群，對於任何暴力徵兆會變得十分敏感，在每次被虐之情境裡，都可能相信自己面臨生命或嚴重身體傷害之立即危險。由此推知，第一、二審判決援引受虐婦女特殊經驗來認定現在不法侵害的真正原因，不是本案情節已經凸顯正當防衛理論本身有改弦更張的必要性，而是對於賈男有無殺人決意的事實不明，卻不知道應該援引罪疑唯輕原則來解決⁶⁴。

63 薛智仁（註26），頁188。

64 另一個同樣遺忘罪疑唯輕原則的例子是「互毆能否主張正當防衛」的問題。對此問題，我國實務自從最高法院30年上字第1040號判例起，即認為「至彼此

2. 受虐婦女創傷症候群作為擴大侵害現在性概念的根據

本案第一、二審判決的勇於突破，對本案或許是一場美麗的誤會，但對於將來情節類似鄧如雯殺夫的家暴事件，具有開啟正當防衛適用可能性的意義。如前所述，長期受虐的鄧如雯是利用丈夫林阿祺睡覺時將他殺死，依據本文所主張的侵害現在性概念，由於林阿祺並未採取具體危及鄧如雯生命或身體的侵害行為，鄧如雯的殺人行為只是在防止她所恐懼發生的侵害，而不是實際的現在侵害，故不構成正當防衛，只可能主張緊急避難而阻卻不法。然而，縱使林阿祺在睡醒後極有可能再度對鄧如雯或其家人施暴，可被認為緊急危難的狀態，但是鄧如雯的殺人行為果真是必要且衡平的避難手段？一般可能認為，鄧如雯除了殺死林阿祺之外，其實可以選擇其他更輕微的避難手段，例如與林阿祺離婚、離家出走、提起民刑事告訴、尋求警察機關的協助等，直接殺死林阿祺是逾越必要性的避難手段，所以不能主張緊急避難。如果事件發生在現在，受虐婦女依1999年起施行的家庭暴力防治法得向法院聲請民事保護令，更凸顯其殺人行為之不必要。其結果是，將來再度發生類似鄧如雯殺夫的事件，行為人至多以其責任能力欠缺或減低或是「其情可憫」等規定取得阻卻刑責或減輕刑罰。

然而，鄧如雯殺死熟睡的施虐者林阿祺以解脫暴力關係，從一般理性人的角度來說或許不合理，但是就其身為受虐婦女而言有其合理性。受虐婦女症候群的心理與行為特徵，主要由「暴力循環」

互毆，又必以一方初無傷人之行為，因排除對方不法之侵害而加以還擊，始得正當防衛論。故侵害已過去後之報復行為，與無從分別何方為不法侵害之互毆行為，均不得主張防衛權。」這段論述容易令人誤以為，最高法院對於互毆行為設立了排除正當防衛權的例外條款，因而掩蓋其涉及訴訟證明問題的本質。尤其在「無從分別何方為不法侵害」的情形裡，表示互毆的行為可能是對他方的現在不法侵害所為之防衛行為，在無法排除此種可能性時，法院應該依據罪疑唯輕原則，使互毆雙方均得適用正當防衛來阻卻不法，而不是無理由地直接否定正當防衛之適用。詳見薛智仁，參與群毆行為之處罰基礎與立法，頁205-231（2002年）。

及「習得無助」兩方面來解釋⁶⁵。「暴力循環」係指丈夫對於妻子的暴力有階段性循環的特徵，第一期是緊張情緒蓄積期，彼此的情緒緊張會不斷升高到雙方無法控制的程度；第二期是暴力期，丈夫以暴力的方式解除緊張關係，除了言語及肢體暴力，經常也伴隨著性虐待與精神虐待；第三期是懺悔期，施暴的丈夫為了與妻子維持關係，會表現出充滿愛意的悔悟，承諾停止暴力，妻子會因此而獲得力量維持彼此的關係，此後的暴力關係便以這三個階段反覆循環。「習得無助」則是伴隨「暴力循環」所出現的現象，受虐婦女在歷經認為自己無法控制的長期暴力之後，會變得被動、無力，認為自己做任何事都無法改變現狀，因而沒有能力逃離痛苦的現狀。由於外在暴力依然不斷出現，受虐婦女會對任何暴力的徵兆變得十分敏感。因此，受虐婦女雖然在施虐者熟睡時殺害之，但是她合理地相信，施虐者會不斷重複地對其施暴，因而遭受生命或身體的嚴重威脅，企圖分手或對外求援也都無法改變受虐的命運，只有利用施虐者熟睡時將其殺害，才有辦法真正終結暴力關係。從受虐婦女的視野來看，其殺害施虐者的行為，正是對直接即將發生的不法侵害所為的最後手段。

因此，有許多學者認為，通說對於防衛情狀的理解，是預設兩個身材與力量相當的男性，在無預謀的情況下發生暴力口角衝突，引發非正當的攻擊，並沒有辦法公平合理地處理受虐婦女所面臨的情況⁶⁶。正當防衛規定無法顧及受虐婦女的特殊性，造成歧視女性的後果，所以建議考量受虐婦女的特殊經驗來修正侵害現在性的判準。例如，林志潔教授主張，所謂的「客觀」應是以「共同主觀」的經驗為基礎，而不是僅以「男性經驗」為基礎，將受虐婦女的主

65 心理學家 Lenore Walker 的理論內容，參考李佳玟（註1），頁39-40；林志潔（註8），頁44；Wanja Andreas Welke, Der „Haustyrannenmord“ im deutschen Straftatsystem. Diskutiert unter Einbeziehung neuerer Tendenzen im common law, ZRP 2004, S. 15 (16).

66 李佳玟（註1），頁42；Welke (Fn. 65), S. 19.

觀認知納入防衛情狀的認定，無損於防衛情狀的客觀判斷⁶⁷。亦有德國學者主張，侵害是否直接即將發生，本來就應該從理性平均公民的事前觀點，就具體情況併同行為人的認知能力來定義，因此，如果以具體個案的情狀以及行為人的經驗視野為基礎，從事前觀點來看，行為人認定侵害直接即將發生是理性的，就存在防衛情狀⁶⁸。亦有德國學者借鑑「暴力循環」觀點，認為施虐者的熟睡不應被視為侵害的中斷，而是應該被理解為不斷循環的暴力處於短暫停歇的階段，朝類似緊急危難概念的方向重新定義現在侵害的概念，開啟受虐婦女適用正當防衛的可能性⁶⁹。類似的看法主張，如果在一段恐怖的家庭關係中，施暴者的行為無法被預測，施暴手段殘酷而且從事性侵害，受虐的家庭成員可謂無間斷地喪失自由及性自主時，或可承認存在所謂持續的侵害（Dauerangriff），藉此賦予其正當防衛權⁷⁰。

3. 修正侵害現在性概念的正當性質疑

現在的問題是，在防衛情狀的認定上，有必要為了免除受虐婦女的刑事責任，就不再堅守一般理性人的標準，而是納入受虐婦女之主觀特殊經驗嗎？

就此，防衛情狀考量受虐婦女之特殊經驗，在普通法國家的正當防衛結構上有其根據。因為，普通法的正當防衛抗辯，是以防衛者主觀上合理相信的情狀為出發點⁷¹，由於行為人基本上就是一般

⁶⁷ 林志潔（註8），頁48。

⁶⁸ *Susanne Walther*, Anmerkung zu BGH, Urteil v. 18. 4. 2002 – 3 StR 503/01, JZ 2003, S. 52 (53 f.); *Susanne Nothafft*, Himmel und Erde – Frauen in Gewaltverhältnissen und die Schwierigkeit, sie zu verteidigen, wenn sie ihren Peiniger töten, MschrKrim 1999, S. 111 (131); *Almuth Voss*, Die Notwehrsituation innerhalb sozialer Näheverhältnisse, 2013, S. 142.

⁶⁹ *Welke* (Fn. 65), S. 19.

⁷⁰ *Felix Herzog*, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Strafgesetzbuch Nomos Kommentar, 3. Aufl., 2010, § 32 Rn. 30.

⁷¹ 關於英格蘭與威爾斯及美國法的正當防衛理論，參考 *Walter Perron*,

理性人，只要一般理性人相信係面臨防衛情狀，即符合提出正當防衛抗辯的要件。如果只有行為人相信自己面臨生命或身體的危險，對一般理性人而言欠缺合理性，就不符合正當防衛抗辯的要件。然而，上述受虐婦女症候群的心理學研究證實，行為人相信自己面臨生命身體的危險，以及最後殺死受虐者的防衛行為，並不是單純出於其個人過於敏感或恐懼，也不是純屬無節制的報復，而是其他長期受虐的婦女所共享的認知及反應。換言之，行為人的認知與反應，雖然在一般理性人的視野下欠缺合理性，但是在一般受虐婦女的視野下具有合理性。因此，為了考量受虐婦女的特殊經驗，在維持以防衛者合理相信的情狀為基礎之下，必須以「一般受虐婦女」標準來取代「一般理性人」標準。此種合理性判準的調整，對於受虐婦女的刑事責任有很大的影響。因為，如果維持一般理性人標準，受虐婦女故意殺死熟睡的施虐者，在不存在其他抗辯事由時，將是故意殺人或謀殺的行為；如果調整為一般受虐婦女標準，將符合正當防衛抗辯而無罪。

相對於此，我國的正當防衛結構及其法律效果比較多元。我國的正當防衛結構，係由客觀要件（防衛情狀及必要之防衛手段）與主觀要件（防衛意思）所組成，必須二者兼具才有阻卻不法的效力。此種結構的最大特徵在於，防衛情狀之存在及防衛手段之必要性作為一個客觀要件，係以行為人主觀意思以外之客觀情狀為判斷基礎，而防衛意思作為一個主觀要件，則是純粹以行為人於行為當時之主觀想像為判斷基礎。因此，防衛情狀究竟存不存在，跟行為人是否合理相信其存在無關。如果行為人誤以為客觀上存在防衛情狀（所謂誤想防衛），那麼他只符合正當防衛的主觀要件，不符合正當防衛的客觀要件，沒有阻卻不法的效力；反之，如果行為人不

Rechtsvergleichende Betrachtungen zur Notwehr, in: Arnold/Burkhardt/Gropp/Heine/Koch/Lagodny/Perron/Walther (Hrsg.), *Menschengerechtes Strafrecht: Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag*, 2005, S. 1019 (1025-1031).

知道客觀上存在防衛情狀（所謂偶然防衛），那麼他只符合正當防衛的客觀要件，不符合正當防衛的主觀要件，一樣沒有阻卻不法的效力。儘管如此，行為人的刑責仍然會因為誤認防衛情狀而受到影響。姑且不論細節上的學說爭議，我們大致上可以說，誤想防衛的行為人不會負故意既遂罪的責任，而是依據其是否可能預見欠缺防衛情狀，分別成立過失既遂罪（或援引過失既遂罪的法律效果）或者無罪⁷²；偶然防衛的行為人不會負故意既遂罪的責任，而是成立故意未遂罪，或是減輕故意既遂罪的法律效果⁷³。即使行為人正確認知防衛情狀的存在，但是在慌亂、恐懼等心理之下採取了過當的防衛手段（所謂防衛過當），基於個案的期待可能性考量，仍可能使其免除或減輕罪責。

在這樣的正當防衛架構之下，縱使我們維持通說所理解的正當防衛要件，受虐婦女殺死熟睡的施虐者無法依正當防衛阻卻不法，在犯罪結構上仍然存在各種管道，考量受虐婦女症候群對行為人的影響，依個案情節來決定是否阻卻故意、阻卻既遂、免除或減輕罪責。例如，暴力的循環使得受虐婦女真摯地誤信，施虐者已經使其生命身體陷入具體危險，而且不可能排除此種認知，其誤想防衛即因為阻卻過失而無罪⁷⁴。此外，習得的無助可能讓受虐婦女不相信，除了殺害施虐者之外還存在其他有效避免現在不法侵害的較輕微手段，以致於難以期待其不殺人，其防衛過當即因為免除罪責而無罪。相同的因素在認定受虐婦女是否適用緊急避難時，也都可能依個案情節發生阻卻不法或減免罪責的效果。簡言之，受虐婦女症候群對於行為人的影響，在我國的犯罪結構中存在不同的出罪管

⁷² 容許構成要件錯誤之處置方式，學說概況僅參考林山田，刑法通論（上），10版，頁440以下（2008年）；吳耀宗，此郎非狼，月旦法學教室，122期，頁27-29（2012年）。

⁷³ 林鈺雄（註6），頁232-234。

⁷⁴ Nothafft (Fn. 68), S. 132.

道，現實上有無必要再針對受虐婦女擴大正當防衛阻卻不法的可能性，已經有待商榷。

前述學說嘗試在防衛情狀的客觀判斷上，就將受虐婦女症候群對行為人認知的影響納入考量，或許是希望直接讓受虐婦女依據正當防衛來阻卻不法，不必再依個案情節從其他管道出罪。不過，我們認為，在一個區分不法與罪責階層的犯罪概念底下，刑法對於行為的不法評價，所訴求的是建立一個獨立於個人的理性行為準則，至於行為人是否有責，則是個人從事該不法行為可否被非難的問題⁷⁵。一個行為究竟是透過哪個管道被出罪，不僅可能影響行為人所承擔的刑事責任，也代表了刑法對於該行為的評價，係肯定其為理性的行為，或只是原諒其不理性的行為。因此，為了確定系爭行為的真正刑法評價，我們需要詳查個案的事實細節，作為評價的基礎。我們不能忽略，所謂的受虐婦女只是一個概括的稱呼，每個被冠上受虐婦女稱謂的行為人，其實各自經歷不同的暴力關係，有獨特的受虐經驗，發生殺害施虐者行為的情節也未必相同，如果簡單地將行為人歸納為受虐婦女，或者認定有受虐婦女症候群，就直接為其套用特殊的防衛情狀判斷標準而一律阻卻其行為之不法，反而是在刑事責任判斷上的粗糙⁷⁶。事實上，從本案第一、二審判決就可以推知，法院似乎正是在思考上過度受到趙女是受虐婦女的牽制，以致於忽略了許多法律上重要的事實細節的確認⁷⁷。因此，概括地為所謂受虐婦女放寬正當防衛阻卻不法的管道，容易在事實認定及法律評價上忽略個案的差異性，可能造成個案不正義的結果。

除此之外，這樣的作法也可能造成違反平等原則的結果。儘管我們也承認，現在不法侵害的判斷本質上是一種事前預測，不過似

⁷⁵ 黃榮堅（註50），頁169-171、177。

⁷⁶ 類似觀點亦見 *Nothafft* (Fn. 68), S. 133 f.; *Rita Haverkamp*, Zur Tötung von Haustyrannen im Schlaf aus strafrechtlicher Sicht, GA 2006, S. 586 (594).

⁷⁷ 本案第一審判決事實認定的瑕疵，詳見李佳玟發言（註58），頁71-74。

乎沒有理由顯示，此種事前預測必須一併將防衛者的認知當成預測的基準，更沒有理由只在行為人是受虐婦女時，才將行為人的認知當成預測的基準。婦女的受虐經驗使其易於誤認面臨生命身體危險，至多是一種對於個人認知能力及其成因的敘述而已，同樣的說法也適用在天生性格極為敏感的人，或是基於家庭暴力經驗以外之後天因素而對於暴力徵兆過度敏感之人，甚至任何出於疏忽而誤認客觀上存在現在不法侵害的人，認真追究起來也都有其先天性格或後天環境上的成因，而且是與其他有相同先天與後天成因的人所共享。從平等尊重個人人格的立場來說，如果在基於家庭暴力經驗以外之因素而影響行為人認知能力的情況，仍然應該維持以客觀上存在現在不法侵害作為阻卻不法的前提要件，那麼為何只是影響的因素是來自家庭暴力的受虐經驗時，就應該推翻這個標準，使受虐婦女的特殊經驗足以影響現在不法侵害的客觀判斷，似乎難以找到適當的解釋。

綜上所述，在普通法的正當防衛結構下，依據受虐婦女症候群的構想來改變防衛情狀的判斷標準，讓受虐婦女不至於僅在成功抗辯心神喪失時才能獲判無罪。但是，在我國的正當防衛結構下，原本就存在多元的出罪管道，沒有擴大正當防衛阻卻不法可能性的絕對必要；概括地為受虐婦女設下特殊的防衛情狀判斷標準，有個案不正義及違反平等原則的疑慮。受虐婦女症候群的心理學觀念對於刑法學的真正價值，並非顯示正當防衛成立要件的不合理，而是提醒我們在理解受虐婦女的認知及防衛反應時，必須意識到其可能擁有不同於其他人的經驗，不應受到一般刻板印象的牽制，也不應執著於一般理性人的經驗，在錯誤理解受虐婦女的社會及心理特質下做出不正確的刑法評價。受虐婦女症候群對於行為人刑責的影響，可能發生在構成要件故意的判斷上，可能發生在不同阻卻不法事由的各個要素上，也可能發生在罪責的認定上，而不是只在正當防衛的領域上，更不足以成為一個改變正當防衛成立要件的事實因素。

(三) 小結

至此可知，正當防衛的侵害現在性標準，尤其在家暴案件裡受到極大的挑戰，不論是概括地以最後有效防衛時點、承認正當防衛之類似情狀，或援引受虐婦女症候群的觀念來修正防衛情狀的標準，都是希望確保受虐婦女有效防衛的可能性，將侵害現在性的射程往前延伸。不過，整體來說，本文認為這些修正觀點忽略了，正當防衛作為最銳利的緊急權限，對於潛在不法侵害者的利益風險極高，為了減少被誤認為即將從事不法侵害的無辜者承受防衛後果的風險，必須在已有客觀事實確認特定客體已陷入具體危險的階段，才能肯定已存在現在不法侵害。此一具體危險的標準固然尚待明確化，但是援引犯罪階段理論的普遍作法，未必有明確化的成效，反而模糊焦點。對於尚未進入此階段的潛在不法侵害採取預防措施，只能在個案中依緊急避難來處置⁷⁸。

伍、防衛手段

一、防衛手段之必要性

在肯定賈男持刀恐嚇係對趙女生命之現在不法侵害之後，接著

⁷⁸ 適用緊急避難的一個核心問題是，受虐婦女有無其他管道來迴避施暴者將來的不法侵害？如同以下將要討論的防衛手段必要性問題（下文伍、一），法官必須貼近現實地確認，其所設想的迴避管道是否真的有效。例如，受虐婦女固然可能離家或借住親友家，但是此種作法通常不是有效的避難方式，因為離家可能使其他的家庭成員陷入無助的狀態，導致受虐婦女不敢離家，或者施虐者可能知道親友的地址，因而以暴力強行帶回受虐婦女，或以其他方法壓迫騷擾。此外，尋求警察援助、聲請保護令或向非官方機構求援等管道，其有效性也取決於個案情況，尤其受虐婦女有無充分資訊得知這些救援管道，實際上是否受到施虐者的長期監控而無法對外求援，這些管道所提供的救援方式成效如何等等。無論如何，不能僅以法律上存在救援管道，就概括地否定受虐婦女避難行為的必要性。詳細討論參考 Schramm (Fn. 54), S. 147 ff.; Hillenkamp (Fn. 54), S. 155.

的問題是趙女持榔頭用力敲擊賈男頭部，是否為必要的防衛手段。對此，第一審及第二審判決均將趙女持榔頭敲擊及持刀刺殺的動作視為整體，而簡短地論述「即便情況急迫，而來不及拿取其他攻擊力較為輕微之器具，本得持榔頭、菜刀朝賈新民手部或其他不致致命之身體部位揮砍，即達防禦嚇阻之作用，乃被告竟捨此未為……顯已逾越當時必要程度之防衛手段，自屬防衛過當。」更審判決更是毫無說理地論斷「被告因而基於殺人及防衛自己生命法益之意思，於該時以逾越必要程度之防衛手段，持榔頭朝賈新民頭部敲擊，固應評價為對現在不法侵害所為之防衛過當行為……。」

學說與實務均公認，正當防衛的防衛手段，必須是可期待確定能排除不法侵害的手段，而且必須是在多種可得採取的有效防衛手段之中侵害最小者。不過另一方面，如果侵害較小的防衛手段可能讓被侵害者額外承擔風險，選擇防衛效果較為可靠但是侵害較大的防衛手段，仍然符合防衛手段必要性的要求⁷⁹。舉例來說，對於一個被他人近身持刀攻擊的人，我們不能硬性地要求他，一定要先赤手空拳地反擊，再使用短刀或槍枝反擊。如果可以確定，赤手空拳地反擊可能使被侵害者承擔防衛失敗的風險，而且在防衛失敗之後，也錯失取出武器有效防衛的時機，此時被侵害者直接使用武器防衛，仍然是一個必要的防衛手段。因此，判斷一個防衛手段是否必要的時候，永遠必須去衡量，依據不法侵害對於法益危險的種類及急迫性，相對於被侵害者實際採取的防衛手段，是否存在其他至少同樣有效而且侵害較小的替代防衛手段。

就此而言，本案更審判決認定趙女持榔頭敲擊頭部係防衛過當，卻完全沒有交代趙女在當時究竟存在哪些侵害更小的替代防衛

⁷⁹ 僅參考 *Roxin* (Fn. 23), § 15 Rn. 42 f.; *Freund* (Fn. 25), § 3 Rn. 105; *Kindhäuser, LPK-StGB* (Fn. 26), § 32 Rn. 31; *Köhler* (Fn. 25), S. 269; *Stratenwerth/Kuhlen* (Fn. 25), § 9 Rn. 82; 黃惠婷，正當防衛之防衛行為，台灣本土法學雜誌，29 期，頁 134-135（2001 年）。

手段，顯然是恣意的判斷。至於第一、二審判決指出，趙女可以持榔頭攻擊賈男的手部或其他較不致命的部位，表面上是交代了趙女存在其他侵害更小的替代防衛手段，但是其如何得出這些替代防衛手段「即達防禦嚇阻之作用」，也難以從判決理由窺知。有學說認為，考量賈男為75歲的老人，趙女持有榔頭，趙女攻擊賈男的其他非要害部位應可排除其侵害能力⁸⁰。然而我們必須注意，賈男的高齡不等於其體弱而無力反擊，趙女持有武器不等於其於搏鬥的情況下也善於使用武器，如果再考量下述的變數就可以發現，趙女的防衛手段有無必要性，並未如判決所言般明確。首先，倘若趙女持榔頭攻擊賈男手部，或許能使賈男所持菜刀掉落，短暫地延緩賈男持刀攻擊的時間，也或許使賈男意識到趙女並非完全順從而戒慎恐懼。不過以賈男長期虐待趙女來說，賈男也可能自認處於掌控趙女的地位，趙女攻擊賈男手部會被視為對其權威的挑戰，反而強化其持刀攻擊趙女的意志，只要賈男仍保有攻擊能力，就有可能取回菜刀或轉換工具（奪下趙女所持榔頭）來接續他的侵害。其次，趙女在多日未進食、身體因導尿管裝置出問題而疼痛難耐的情況下，不管其身材或肢體衝突經驗如何優異，一旦其攻擊賈男手部不成功，反而激怒賈男採取更強烈的攻擊，很可能會陷入任由賈男攻擊而無從抵抗的狀態。如果綜合考量這些變數，趙女趁著賈男不及反應時以隨手可得的榔頭敲擊其頭部，就成為一個能夠可靠地排除賈男的攻擊能力、使自己不會承受額外風險的防衛手段。因此，我們實在很難如同本案第一、二審判決般，肯定趙女持榔頭攻擊頭部係「顯然」逾越必要程度的防衛手段⁸¹。尤有甚者，這兩則判決竟然一方面在防衛情狀的認定上，強調必須貼近受虐婦女的特殊心理經驗，不宜維持一般理性人的判斷標準，另一方面在防衛手段必要性的認定上，卻又完全不去考量趙女實際上所擁有的防衛可能性，任意地

⁸⁰ 高金桂（註17），頁122。

⁸¹ 相同質疑：張天一（註16），頁179-180。

假定一個昧於現實的替代防衛手段，否定其防衛行為的必要性，這前後立場的矛盾實在顯而易見。

依據作者有限的觀察，此種以昧於現實的經驗法則判斷防衛手段必要性的判決，在我國實務上似乎相當普遍，殺人行為幾乎都被認定為防衛過當，沒有阻卻不法的餘地。實務如此嚴格地認定防衛手段之必要性，可能只是擔心，在被告的防衛手段造成重大傷亡的時候，如果不判決其有罪，可能會向公眾傳達錯誤的訊息，以為殺人可以不用被處罰。然而，問題是，現行法的正當防衛既然對防衛手段只有必要性的限制，只要符合此一要件，甚至被害人或第三人也有權殺死一個手無寸鐵的竊賊，就算這樣的結果可能違反法官的倫理觀念或刑事政策觀念，法官也必須受到現行法的拘束，而不是以悖離現實的假設來否定行為人依正當防衛阻卻不法的機會⁸²。從刑事政策的觀點來看，如果國家要求公民在遭遇不法侵害時，有義務採取一個只存在昧於現實的法官幻想中的最小侵害手段，等於是強迫公民直接向不法侵害投降，禁止擁有市民勇氣的公民援助他人，以被侵害的公民為代價來保障不法侵害者的利益，間接地鼓勵不法侵害。因此，未來法院應該更貼近現實地判斷，如果被侵害者採取一個更輕微的替代防衛手段，是否有很大的可能性，反而讓不法侵害者對他或提供救助的第三人造成傷害。這種貼近現實的判斷，有賴於法院擁有最低限度的專業知識，必要時應選任鑑定人（例如：警察訓練教官，搏擊運動教練等）來輔佐自己判斷，而不是依據自己的想像來判斷。

82 Volker Erb, Zur Aushöhlung des Notwehrrechts durch lebensfremde tatrichterliche Unterstellungen – Zugleich eine Besprechung von LG München I, Urt. V. 9. 1. 2009 – 1 Ks 121 Js 10459/08 („Fall Sven G.“), NStZ 2011, S. 186 (191).

二、防衛手段之合宜性

(一) 緊密的個人關係作為防衛手段之社會倫理限制

通說認為，在侵害者與防衛者之間存在緊密的個人關係（*enge persönliche Beziehungen; soziale Näheverhältnisse*）時，防衛手段不僅要符合必要性，另外受到社會倫理的限制，如果不符合此種限制，防衛手段即欠缺合宜性（*Gebotensein*）。基於這樣的限制，防衛者要格外注意保護不法侵害者的生命與身體完整性，盡量迴避其所實施的不法侵害。如果不法侵害不會導致嚴重的傷害，有時為了避免殺死不法侵害者，甚至只能採取比較不可靠的防衛手段，忍受身體輕微受傷的可能性⁸³。

此處所稱「緊密的個人關係」的射程，在德國實務及學說上並不一致。早期實務將緊密的個人關係理解得比較寬鬆，同一家公司的員工或是同一個運動團體的會員都包含在內，後來的實務則是理解得比較嚴格，幾乎將其與家庭關係劃上等號⁸⁴。德國文獻基本上也是從嚴理解，僅限於關係緊密的家庭關係或緊密程度相當的其他關係，其成員的防衛手段才會受到社會倫理的限制。不過，大多數學說認為，並不是只要侵害者與防衛者之間具有夫妻或父母子女的地位即可，二者之間的關係必須原則上沒有破損，才稱得上彼此有緊密的個人關係。因此，如果家庭生活或彼此的關係，已經因為侵害者先前反覆的施加暴行而嚴重破損，那麼防衛者的防衛行為不受社會倫理的限制⁸⁵。部分學說更進一步主張，只有在彼此關係沒有破損，而且侵害者係一次性地突然失控而逾越言語衝突的界限時，

83 BGH, NJW 1969, 802 (802); 1975, 62 (62 f.).

84 BGH, GA 1969, 117 (117); BGH, NJW 1969, 802 (802); BGH, NJW 2001, 3200 (3202).

85 Roxin (Fn. 23), § 15 Rn. 95, 97; Rönnow/Hohn (Fn. 21), § 32 Rn. 241; Ulrich Schroth, Notwehr bei Auseinandersetzungen in engen persönlichen Beziehungen, NJW 1984, S. 2562 (2563); 余振華，刑法違法性理論，2版，頁196（2010年）。

才有討論社會倫理限制的餘地⁸⁶。依此，儘管賈男與趙女在法律上仍是夫妻，但是從兩人分居及先前賈男對趙女的長期言語肢體暴力來看，彼此的關係基本上已經破損，所以趙女在面對賈男的持刀恫嚇時，防衛手段只要遵守必要性的限制，不適用基於緊密個人關係而來的社會倫理限制。亦即，如果趙女持榔頭敲擊賈男頭部已經是必要的防衛手段，即可適用正當防衛阻卻不法。

國內文獻也多數肯定此種限制，認為如果不對家庭成員的防衛手段加以限制，會與攻擊者的保證人地位產生衝突⁸⁷，而且無異於間接鼓勵且加深家庭倫理的破壞⁸⁸。對於此一學說立場，我國實務向來不曾表態，本案的第一審判決卻罕見地指出，此種忍受共同生活體成員不法侵害的義務，並不是保證人義務的內容，也無法以維持家庭倫理的道德要求為根據，甚至進一步提出，此種對正當防衛權的限制違反罪刑法定原則⁸⁹。由於此一問題在家暴事件中特別具有重要性，所以有必要對上述爭議詳加分析。

（二）違反罪刑法定原則的限制

承認緊密個人關係作為防衛手段的社會倫理限制是否牴觸罪刑法定原則，主要牽涉到兩個問題。第一個問題是：刑法總則的法定阻卻違法事由有無罪刑法定原則之適用？第二個問題是：在正當防衛承認社會倫理的限制，是否牴觸罪刑法定原則？

針對第一個問題，罪刑法定原則在刑法總則領域有其適用，應是沒有疑問的。從權力分立原則來說，罪刑法定原則確保由具有直接民主正當性的立法者來決定國家刑罰權的範圍。由於每個犯罪之

⁸⁶ Wolfgang Wohlers, Einschränkungen des Notwehrrechts innerhalb sozialer Näheverhältnisse, JZ 1999, S. 434 (441); Rönau/Hohn (Fn. 21), § 32 Rn. 241.

⁸⁷ 林鈺雄（註 6），頁 256；林山田（註 72），頁 330-331；黃惠婷（註 79），頁 136；余振華（註 85），頁 195-196。

⁸⁸ 黃常仁，刑法總論，2 版，頁 59（2009 年）。

⁸⁹ 不同見解：高金桂（註 17），頁 123。

成立要件及法律效果，都是由刑法分則與刑法總則的規定所共同決定的，如果允許法官類推適用刑法總則的規定，無異於讓法官也能自行決定國家刑罰權的範圍，這與權力分立的精神不符合。基此，在刑法總則的規定之中，如果是超出刑法分則的範圍而擴張刑罰的規定，例如未遂犯（刑法第25條）、正犯與共犯（刑法第28條以下）等，即禁止法官類推適用。同樣的，如果是法定的阻卻罪責（刑法第16條、第18條、第19條第1項等）、阻卻或減輕刑罰（刑法第20條、第26條）或解除刑罰事由（刑法第27條），也不能附加超出法條文義的限制⁹⁰。舉例來說，在2005年刑法修正之前，尚無原因自由行為的特別規定，如果行為人故意喝醉酒而在無責任能力的狀態下殺人，法院應依當時的刑法第19條第1項諭知無罪，如果援引原因自由行為理論而排除其適用，即係對於阻卻罪責規定附加超出法條文義的限制，因而違反罪刑法定原則⁹¹。於是立法者在2005年增訂刑法第19條第3項，解決了此項爭議。

不過，上述觀點也適用在刑法典的法定阻卻違法事由嗎？一個最明顯的例子是，我國學說上經常提到，在避難者故意自招危難的時候，其避免自己危難的行為不適用緊急避難而合法化⁹²，但是這顯然超出刑法第24條第2項的例外條款的文義。那麼在立法者修法承認之前，法官可以直接援引通說見解，認定避難行為仍然違法嗎？對此，部分文獻主張，既然法定阻卻違法事由也是一個共同決定國家刑罰權範圍的因素，如果法官對其附加法條文義所沒有的限制，等於是變相地自行擴大國家刑罰權，所以應該與前述的阻卻罪

90 參考 *Roxin* (Fn. 23), § 5 Rn. 41.

91 林鈺雄（註6），頁311；鄭逸哲，罪刑法定主義七十年，收於：余振華、林山田、林東茂、柯耀程、許玉秀、黃朝義、鄭善印、鄭逸哲著，刑法七十年之回顧與展望紀念論文集（一），頁104-105（2001年）。相對於此，劉幸義，罪刑法定主義的理論與實務批判（上），刑事法雜誌，38卷5期，頁73（1994年）認為，「原因自由行為」儘管是不利行為人之習慣法，仍然可以被視為責任原則的內涵而予以承認。

92 僅參考：林鈺雄（註6），頁272。

責或刑罰等刑法總則規定一樣，適用罪刑法定原則⁹³。反對見解則是認為，法定阻卻違法事由並不是專屬於刑法的規定，而是也可能來自刑法以外的法領域，法官對這些規定經常不用受到法條可能文義的拘束，只要依據該規定的基本精神來限制其適用範圍即可，刑法基於維護法秩序一體性，對此必須加以接受。至於規定在刑法典的法定阻卻違法事由，因為也一體適用於其他法領域，所以沒有必要強行要求其適用於其他法領域時遵守罪刑法定原則。因此，法定阻卻違法事由不受法條文義的拘束，法官只要依據其立法目的來作解釋⁹⁴。

本文認為，刑法典的法定阻卻違法事由既是決定國家刑罰權射程的一環，其亦應適用罪刑法定原則，以確保個人對可罰性範圍的可預見性，司法權不得逾越立法者的決定而擴大刑罰權。學說上所提出的反對理由，亦即阻卻違法事由亦適用在其他法領域以及法秩序一體性，並無排除罪刑法定原則適用的效力。因為，不論如何地強調法秩序一體性原則，各個法領域依舊有其獨特的規範目的及法律效果，其對於一個行為做成不法（或違法性）的評價，目的僅在於連結其各自的法律效果，而不是在強迫其他法領域接受其不法評價，作為連結法律效果的根據。正如同擅自使用他人汽車後歸還的行為，固然是一個民事不法的侵權行為，但不是一個刑事不法的竊盜行為，因而只負損害賠償責任，而不是負擔刑事責任。以此為出發點，刑法典的法定阻卻違法事由固然適用在所有法領域，但是法秩序一體性原則仍然容許在不同法領域採取不同的解釋。亦即，在這些阻卻違法事由適用於其他法領域，也就是連結民法或公法上的法律效果時，沒有必要受到罪刑法定原則的拘束，所以允許法官不受文義拘束地限縮其適用範圍，但是當這些阻卻違法事由適用於刑

⁹³ Engländer (Fn. 21), Vor §§ 32 Rn. 10; Erb (Fn. 26), § 32 Rn. 179 ff.; Rönau/Hohn (Fn. 21), § 32 Rn. 228.

⁹⁴ Krey/Esner (Fn. 26), Rn. 94; Roxin (Fn. 23), § 5 Rn. 42, § 15 Rn. 56; 陳俊榕，論「挑唆防衛」，國立中正大學法學集刊，39期，頁82-84（2013年）。

法領域，也就是連結刑法的法律效果時，法官仍然應該謹守罪刑法定原則，不能超出法條文義地限縮其適用範圍。換言之，在連結刑法的法律效果時，法定阻卻違法事由應受到罪刑法定原則之拘束。

就此處所討論的問題而言，如果我們主張法定阻卻違法事由不得受到超出法條文義的限縮適用，對防衛行為附加社會倫理的限制，是否已經超出法條的可能文義呢？這就涉及了上述的第二個問題⁹⁵。刑法第23條本文規定「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。」在文義上未對防衛行為的尺度作任何限制，普遍被承認的防衛手段必要性及合宜性限制，似乎是對於正當防衛權附加超出法條文義的限制。不過，一併觀察該條但書「但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。」即知，立法者已經透過「防衛行為過當」的用語，表達防衛行為應該遵守一定的尺度，只是這個尺度究竟是採取「必要性」標準，或是包括「社會倫理限制」或「合宜性」在內，法條文義本身保留了一個開放的空間。因此，通說對於防衛手段附加必要性或合宜性的要求，仍在法條文義的容許範圍內，沒有違反類推適用禁止原則。比較大的問題是，結合必要性與社會倫理限制（合宜性）作為判斷防衛行為「過當」與否的標準，使得正當防衛的阻卻違法要件變得較為不明確，是否已經達到違反明確性原則的程度？對此，本文傾向持肯定立場。初步的理由是：防衛手段的尺度為何，是一個確定國家刑罰權射程的因素，其重要性不亞於各罪的構成要件要素，立法者有義務清楚地指出防衛手段的尺度，而不是僅僅指示防衛過當的法律效果。如果立法者不得已必須使用不明確的概念，在法律適用的層次上，也應該盡可能地使系爭法律變得更具體，使受規範之人可以預見行為的可罰性，而不是加深法律的不明確性⁹⁶。就此而言，附加社會倫理限

⁹⁵ 德國法的討論，僅參考 *Schroth* (Fn. 85), S. 2562 ff.; *Erb* (Fn. 26), § 32 Rn. 204 f.; *Rönnau/Hohn* (Fn. 21), § 32 Rn. 228.

⁹⁶ 依據德國聯邦憲法法院之正確見解，明確性原則不僅是對立法者的要求，同時也是對於適用法律者的要求，參考 BVerfGE 126, 170 (196 ff.).

制作為防衛手段的判準，就產生法律更不明確的危險。因為，學說所列舉的社會倫理限制事由，不僅在我國實務上尚未被採納，而且未必能從正當防衛的制度功能（保護個人利益及確認法秩序之效力）推導出來⁹⁷，若是對照德國法的發展，其案件類型還可能隨著時間而增加⁹⁸。這一切都表示，所謂正當防衛權之合宜性或社會倫理的限制，其射程有多遠尚處於變動不居的狀態，條文所稱的「防衛過當」很難稱得上已經在事後透過學說及實務的發展而獲得穩定的意涵，存在國家刑罰權射程由法官恣意決定的風險⁹⁹。據此，正當防衛的現行規定過於不明確，防衛行為的合宜性或社會倫理限制更是加深其不明確程度，故牴觸罪刑法定原則。

（三）欠缺實質正當性的限制

除了為防衛行為附加社會倫理的限制違反罪刑法定原則之外，另一個問題是這個限制有無實質正當性。對此，除了上述國內文獻繼受德國學說所提到的保證人地位觀點之外，德國文獻上另外也有從正當防衛的制度功能角度切入，說明在侵害者與防衛者存在緊密的個人關係時，其保護個人利益或確認法秩序效力的目的必須某程度上退讓。以下依序分析，這些觀點是否足以正當化這項限制。

1. 保護者保證人地位觀點

有不少學說認為，緊密的個人關係構成對防衛行為之社會倫理限制，理由在於防衛者對於侵害者居於保護者保證人地位

⁹⁷ 不同見解：Jescheck/Weigend (Fn. 24), § 32 III 3; Rengier (Fn. 23), § 18 Rn. 54.

⁹⁸ Volker Erb, Gegen eine Inflation der „sozialethischen Einschränkungen“ des Notwehrrechts, in: Kühl/Seher (Hrsg.), Rom, Recht, Religion, 2011, S. 329 ff.

⁹⁹ 參考 Volker Erb, Die Schutzfunktion von Art. 103 Abs. 2 GG bei Rechtfertigungsgründen. Zur Reichweite des Grundsatzes „nullum crimen sine lege“ unter besonderer Berücksichtigung der „Mauerschützen“-Fälle und der „sozialethischen Einschränkungen“ des Notwehrrechts, ZStW 108 (1996), S. 266 (294 ff.); Erb (Fn. 26), § 32 Rn. 205; Engländer (Fn. 21), § 32 Rn. 42; Rafael van Rienen, Die „sozialethischen“ Einschränkungen des Notwehrrechts, 2009, S. 176 f.

(Beschützergarantenstellung)，對其法益負有特別保護或關照的義務，所以正當防衛的確認法秩序效力目的，不能完全發揮作用，或必須退居次要的地位¹⁰⁰。不過，保證人地位原本的功能是在建構不純正不作為犯的可罰性（刑法第15條），唯有居於保證人地位之人的不作為才會與作為等價。例如，妻子故意不將生病的丈夫送醫，導致丈夫延誤治療而死亡，由於妻子對於丈夫的生命及身體有保護義務，其未將丈夫送醫的不作為，會成立不作為殺人既遂罪。現在的問題是，保證人義務的內涵是否能被轉換為，妻子在面臨受其保護的丈夫的不法侵害時，不得行使完整的正當防衛權？

就此，或許有人認為，既然保護者保證人的義務內涵就是保護他人的法益，達成此一目標的途徑，除了在他人的法益陷入危難時提供必要的救助以外，也包括不得對其採取特別危險的防衛行為。換言之，提供必要的救助（作為義務）與放棄危險的防衛（不作為義務）是一體兩面，保護者保證人地位既可以成為不純正不作為犯的入罪根據，也可以成為防衛行為的限制理由。不過，此種推論忽略了：保護者保證人並不是無時無刻對他人負有保護義務，而是只有在被保護人的法益陷入危險，因而處於需要他人救助的狀態時，才會真正啟動其保護義務。並且，縱使在被保護者需要他人救助的時候，如果此一危險狀態來自被保護者的自主決定，基於尊重個人的自主決定權（或避免保證人成為他人的監護人），保證人也沒有阻止此危險實現的義務¹⁰¹。舉例來說，對於一個生意失敗而準備自殘的先生，只要先生係出於自主意思而決定自殘，妻子不會因為未阻止先生自殘而成立犯罪。從這個角度來看，我們很難從防衛者對於侵害者居於保證人地位，衍生出限制其防衛行為的內涵。因為，

¹⁰⁰ Roxin (Fn. 23), § 15 Rn. 93 ff.; Erb (Fn. 26), § 32 Rn. 219; Rengier (Fn. 23), § 18 Rn. 68; Kindhäuser, AT (Fn. 26), § 16 Rn. 47; Kindhäuser, LPK-StGB (Fn. 26), § 32 Rn. 52; Köhler (Fn. 25), S. 275; Krey/Esser (Fn. 26), Rn. 538; Heinrich (Fn. 25), Rn. 381 f.; Wessels/Beulke (Fn. 54), Rn. 345.

¹⁰¹ Rengier (Fn. 23), § 50 Rn. 40; Kühl (Fn. 26), § 18 Rn. 60.

實施不法侵害之人，其實也認知到可能承受他人防衛行為的後果，並且認知到只要立刻終止自己的不法侵害，他方不僅在法律上沒有防衛的權利，事實上也通常會隨即放棄其防衛行為，如此即可解除自己法益喪失的危險。換言之，在實施侵害行為的當時，侵害者係有意識地自陷風險，並不是處於需要他人救助的狀態，防衛者的保護義務尚未真正啟動，所以沒有據此限制其防衛行為的效力¹⁰²。

另外要注意的是，如果以防衛者對侵害者居於保護者保證人的理由來詮釋防衛行為的社會倫理限制，邏輯一貫的結果是：此一限制不僅適用於婚姻或家庭成員之間，也應該一體適用於其他保護者保證人的類型裡¹⁰³。舉例來說，接收病患治療的急診醫師，基於其自願承擔保護義務而對病患居於保護者保證人地位，在面臨不滿等待過久的病患動手毆打時，不得採取必要的防衛手段；一起攀登高山的登山團員，基於危險共同體而對其他團員居於保護者保證人地位，在其他團員欲搶奪其維生設備時，同樣不得採取必要的防衛手段。如此一來，隨著保護者保證人的射程越廣，防衛行為之社會倫理限制的適用範圍，就會擴大到至今沒有學說承認的案件類型，導致正當防衛權所受到的限制，變得漫無界限。如果學說堅持此一限制只適用於存在緊密的個人關係的情形，不能擴大到其他保護者保證人地位的案件類型，那麼就必須指出此種區別對待的關鍵理由為何。然而迄今為止，這個層次的說理尚不存在。

¹⁰² 參考 *Engländer* (Fn. 21), § 32 Rn. 48; *Helmut Frister*, Die Notwehr im System der Notrechte, GA 1988, S. 291 (308 f.); *Frank Zieschang*, Einschränkung des Notwehrrechts bei engen persönlichen Beziehungen?, Jura 2003, S. 527 (530); *Nikolaos Bitzilekis*, Die neue Tendenz zur Einschränkung des Notwehrrechts, 1984, S. 124; *Carl-Friedrich von Scherenberg*, Die sozialetischen Einschränkungen der Notwehr, 2009, S. 168 ff.; *Schramm* (Fn. 54), S. 113; *Vöss* (Fn. 68), S. 147; 張天一，對正當防衛受社會道德限制之再檢討——以正當防衛阻卻違法之實質根據為中心，刑事法雜誌，45 卷 4 期，頁 107（2001 年）。

¹⁰³ *Zieschang* (Fn. 102), S. 530; *Schroth* (Fn. 85), S. 2563; *Bitzilekis* (Fn. 102), S. 124 f.; *Schramm* (Fn. 54), S. 113; *von Scherenberg* (Fn. 102), S. 170.

2. 特別連帶義務觀點

另一個經常被提出的理由是：在緊密的個人關係成員之間，彼此互負特殊的連帶義務與關照義務（Solidaritäts- und Rücksichtnahmepflicht），防衛者所負擔的這項義務並不會因為他方對其實施不法侵害而被解除，有鑑於繼續存在的特別連帶義務，正當防衛所欲達成之確認法秩序效力的目標必須退讓¹⁰⁴。相對於援引保護者保證人的觀點，此處所稱之特別連帶義務的內涵及射程，不再受到保護者保證人概念的牽制，可以彈性地被理解為，家庭或婚姻內部成員之間負有相互體諒遷就的義務，標示出家庭成員與陌生第三人的關係仍屬有別。

不過，此種彈性正好就是特別連帶義務概念的缺點。使用此一概念的學說，幾乎沒有進一步解釋，究竟特別連帶義務的內涵是什麼，以及其法律效果為何¹⁰⁵。我們多少可以理解，這個概念可能在表達，家庭成員在相處上難免有衝突，此時應該盡量體諒及遷就他方。不過，如果這種特別義務僅止於對個人的家庭倫理要求，其效果應該也停留在倫理上要求個人相忍為國，而不是進而禁止個人以特定方式行使正當防衛權，使其承擔其於法律上原本無庸忍受的損害，甚至在違反此一限制時承擔刑罰。更重要的是，既然此種特別連帶義務係一體地適用於侵害者與防衛者，那麼我們也難以理解，為何只是片面地要求防衛者，必須格外地關照侵害者不會遭受致命的防衛後果，而不是回過頭來告訴侵害者，既然他已經嚴重地不體諒、尊重防衛者的利益在先，其所實施的不法侵害的可非難程度比其他陌生人更高，當然就更沒有立場繼續期待防衛者仍然會特別關照其利益。很清楚的，一個對他方違反特別連帶義務的人，沒有權

104 Jescheck/Weigend (Fn. 24), § 32 III 3. a); Kühl (Fn. 26), § 7 Rn. 203; Rönnau/Hohn (Fn. 21), § 32 Rn. 239.

105 Zieschang (Fn. 102), S. 530.

利片面要求他方必須對自己謹守特別連帶義務¹⁰⁶。

強調緊密個人關係之成員彼此互負特別的連帶義務，另一個可能的用意是，避免只是因為尋常家庭或婚姻生活中偶發的口角或肢體衝突，受到不法侵害的一方就有權對於輕微犯錯的他方採取激烈的反應。一個極端的例子是：先生為了買煙，擅自從妻子的皮包裡偷走一百元，及時察覺的妻子喝令先生放下一百元未果，便朝先生頭部開槍射殺之。以素樸的法感覺來說，為了保全一百元而殺人是一個過當的反應，妻子的殺人行為不應依正當防衛阻卻不法。不過，妻子的殺人行為不能構成正當防衛，很有可能不是來自於防衛者對於侵害者違反了所謂的特別連帶義務，而是從適用於任何人的正當防衛要件本身就能推導出來的結論¹⁰⁷。首先，就防衛行為必要性而言，如果妻子透過鳴槍警告、過肩摔、毆打成傷或槍擊其他部位的方式，同樣能夠阻止先生取走一百元，其開槍殺人就絕對不是一個必要的防衛行為，因而無法阻卻不法。其次，如果情況極端，唯有開槍殺人才能有效保全一百元，此一防衛行為也可能因為保全的利益與犧牲的利益之間顯然失衡，而受到社會倫理的限制。情況如果再更極端一點，這一百元原本就是妻子故意設計來讓先生「偷」的，妻子意圖藉由阻止先生「偷」錢而達成殺人的真正目的，此時也可以直接適用挑唆防衛的規則¹⁰⁸，而否定殺人行為之合法性。由此可知，促使學說贊成緊密的個人關係構成防衛行為受社會倫理限制的情形，依據個案情節的不同，有些是欠缺防衛手段必要性，有些構成其他類型的社會倫理限制，這些限制並不是緊密的個人關係所獨有，而是防衛者在面對任何侵害者時所應負的最小限

106 參考 *Freund* (Fn. 25), § 3 Rn. 124; *Gropp* (Fn. 23), § 6 Rn. 87; *Kurt Seelmann*, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., 2009, S. 72; *Engländer* (Fn. 21), § 32 Rn. 48, *van Rienen* (Fn. 99), S. 288 f.

107 *von Scherenberg* (Fn. 102), S. 172 f.; *van Rienen* (Fn. 99), S. 291; *Voss* (Fn. 68), S. 150 f.

108 詳細討論：陳俊榕（註 94），頁 84-100。

度連帶義務，我們並沒有必要將緊密的個人關係承認為一個獨立的社會倫理限制類型。

3. 維持婚姻家庭制度觀點

前面的保護者保證人地位及特殊的連帶義務觀點，無法成為社會倫理限制的實質根據，剩下的可能觀點是：通常作為緊密個人關係基礎的婚姻或家庭制度本身，就足以限制正當防衛目的之實現，亦即確認法秩序效力¹⁰⁹或保護個人利益的目標¹¹⁰應該退讓，如果要求絕對貫徹正當防衛的目的，反而不利於婚姻或家庭的存續。此一看法似乎認為，在婚姻或家庭裡面，法的效力某程度上必須退讓，其成員的利益也不能享有法律的完全保護。然而，在面對家庭成員的不法侵害時，維繫家庭或婚姻的價值有多高，基本上應該由被害的家庭成員自己來衡量¹¹¹，而不是由法律概括地代替他決定，維繫家庭婚姻存續的利益永遠都比起保護自己的利益更加優越。換句話說，如果他為了維繫家庭或婚姻的存續而選擇忍受不法侵害，法律固然沒有強行保護其利益的餘地，但是如果他選擇寧可家庭或婚姻破碎也不願意忍受不法侵害，那麼就必須承認：婚姻或家庭並不是法外空間，從來就沒有為其成員創造出一個特殊的權利，可以對其他成員施加身體暴行，也沒有科予其成員一個特殊的義務，必須容忍其他成員所施加的暴行。如果法律在家庭及婚姻領域裡，不堅持禁止任何侵害他人的行為，要求個人忍受一定程度的不法侵害，將會使得通常更需要被保護的弱勢者（婦女及孩童），單純基於其處於婚姻或家庭之中的事實，而被國家拒絕提供必要的保護，

109 Roxin (Fn. 23), § 15 Rn. 93; Murmann (Fn. 54), § 25 Rn. 100; Bitzilekis (Fn. 102), S. 125.

110 Bernd Schünemann, Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft nach der Strafrechtsreform im Spiegel des Leipziger Kommentars und des Wiener Kommentars, 1. Teil: Tatbestands- und Unrechtslehre, GA 1985, S. 341 (369).

111 參考 Otto (Fn. 40), § 8 Rn. 91; Engländer (Fn. 21), § 32 Rn. 48.

反而使其更易於陷入生命危險¹¹²。此一結果與刑法的保護法益目的相牴觸。

對於上述批評，文獻上有認為言過其實，因為此處僅是在情節較輕微的不法侵害限制家庭成員的正當防衛權，刑法對於實施不法侵害之人仍然會追究其傷害罪或強制罪的刑事責任，在此範圍內被害人的法益依然獲得法律的保障¹¹³。不過，我們在這裡批評被害人的利益未受到保護，所指的意思不是刑法不追究不法侵害者的刑事責任，而是指被害人在來不及受到國家援助的時候，面對現在不法侵害卻無法自力救濟，此種自我保護可能性的限縮，是不可能用事後追究不法侵害者的刑責來替代或彌補的。因為，正當防衛不是刑罰，其目的不在於對已經發生的犯罪施加制裁，而是在侵害尚未終局發生之前，就能有效地避免其發生，所以正當防衛權的存在與否，自始就與不法侵害者能否被追究刑責無關。基此，我們沒有理由強迫被害人，在還能夠避免侵害發生的時候，只能眼睜睜地忍受法益侵害的後果，然後寄望國家事後追究不法侵害者的刑責。如果我們再考慮到，許多關於家庭暴力的研究指出，儘管家庭暴力的型態經常是刑法上的非告訴乃論之罪（重傷害、恐嚇、強制、性侵害等），但是被害人通常沒有提出告訴的意願，以致於這些家庭暴力不太會被檢警知悉，限制被害者的正當防衛權，實際上反而伴隨著刑法及程序上有利於侵害者的後果¹¹⁴。因此，不法侵害者仍須負擔刑責，不是承認被害人防衛權限制的充分理由。

（四）小結

綜上所述，緊密的個人關係不應構成對防衛行為的社會倫理限

112 結論相同：Renzikowski (Fn. 54), S. 311.

113 Schramm (Fn. 54), S. 115.

114 Voss (Fn. 68), S. 141 f.

制¹¹⁵。這個主張並不是說，家庭成員或夫妻之間的防衛行為不受任何限制，其真正的意思是，其防衛行為跟其他人之間的防衛行為受到相同的限制，必須依個案情節來認定防衛尺度何在¹¹⁶。因此，一方的小過錯並不會馬上使他方獲得採取致命防衛手段的權利，擔心這會鼓勵夫妻爭吵直到劍拔弩張，其實純屬多餘。至於在防衛者採取危及侵害者生命或身體的正當防衛行為之後，固然不會基於危險前行為而負有救助義務¹¹⁷，但是仍然可能基於親屬關係或生活共同體而負有救助義務。據此，本案第一審判決否定此種社會倫理限制，是一個理由及結論皆正確的看法。

陸、防衛過當

本案的最後一個問題在於如何評價趙女持刀刺殺賈男的行為。可以確定的是，賈男遭趙女持榔頭攻擊倒地之後尚未死亡，趙女刺殺的行為有加速賈男死亡的效果，趙女也正確認識此部分的事實，故其該當殺人既遂罪之構成要件。此外，依據鑑定結果，賈男倒地之後已經意識昏迷、無法站立，因此不僅先前的持刀恐嚇侵害已經被排除，其繼續持刀攻擊趙女生命的能力也已經喪失，趙女在客觀上並未面臨現在侵害，其殺人行為不符合正當防衛之客觀阻卻不法要件，是一個違法的殺人行為。

然而，在罪責層次上如何評價趙女的行為，就存在多個必須考

115 *Fischer* (Fn. 20), § 32 Rn. 37; *Freund* (Fn. 25), § 3 Rn. 125; *von Scherenberg* (Fn. 102), S. 175.

116 相同看法：*Otto* (Fn. 40), § 8 Rn. 92; *Renzikowski* (Fn. 54), S. 311 f.

117 通說認為，危險前行為保證人地位以違背客觀義務之前行為為限，故正當防衛行為人對於不法侵害者沒有救助義務，僅參考林山田，*刑法通論（下）*，10版，頁 255-257（2008年）。縱使是主張前行為不以違背義務為前提者，也認為正當防衛行為應構成例外情況，參考黃榮堅（註48），頁 728-731；*Otto* (Fn. 40), § 9 Rn. 81.

量的觀點。首先，本案第一、二審判決認定，趙女刺殺賈男的行為係「擔心賈男反擊」所為，倘若屬實，則可能構成誤想防衛（Putativnotwehr）。但是，從判決引述趙女的應訊內容來看，她在當時其實正確認知到，賈男在被她持榔頭敲擊之後就倒地不動。這表示趙女知道賈男沒有立刻起身攻擊的可能性，所以她並未誤認存在現在不法侵害，判決中關於趙女「擔心賈男反擊」的敘述，至多表達出趙女擔心賈男在不確定的將來會挾怨報復。因此，趙女刺殺賈男不是一個誤想防衛。其次，如果趙女認為她擔心賈男反擊而殺之係阻卻不法的正當防衛行為，她就成立禁止錯誤，依可避免性存否而決定係減輕罪責或阻卻罪責（刑法第16條）。不過，從判決事實難以窺知趙女有此想法，所以本案也沒有禁止錯誤的問題。

比較明顯的是，趙女在緊接著賈男的不法侵害結束之後，可能係延續先前混亂、恐懼或驚慌的情緒而殺害賈男，構成減免罪責的防衛過當（刑法第23條但書）。對此，我國通說及實務主張，該條但書的防衛過當，僅適用於客觀上存在現在不法侵害，但是防衛行為逾越必要性或合宜性的情形¹¹⁸，也就是德國學說所稱的「強度型防衛過當」（intensiver Notwehrexzess）。然而，本案趙女殺害賈男的行為，並不是防衛情狀存在之下逾越防衛行為的尺度，而是自始逾越防衛情狀的時間限制，也就是德國學說所稱的「延展型防衛過當」（extensiver Notwehrexzess）¹¹⁹。因此，依據我國通說見解，既

118 參考最高法院 97 年度台上字第 3257 號刑事判決；黃常仁（註 88），頁 98；林山田（註 72），頁 402；林鈺雄（註 6），頁 258-259、306-307；柯耀程（註 45），頁 92；吳耀宗（註 72），頁 27；張天一，正當防衛之成立要件與防衛過當之處置方式（下），刑事法雜誌，46 卷 2 期，頁 87（2002 年）。

119 這組概念的中文翻譯相當分歧，本文所採之譯語係援引自：許恒達，延展型過當防衛，月旦法學教室，114 期，頁 33-35（2012 年）。國內文獻上另有譯為「緊縮的防衛過當」與「擴張的防衛過當」者（張天一（註 118），頁 67），亦有譯為「密集的防衛過當」與「擴張的防衛過當」者（柯耀程（註 45），頁 97）。日本刑法學上則稱之為「質的過剩」與「量的過剩」，並基於責任減少說肯定「量的過剩」係過剩防衛而得減免刑罰，參考佐伯仁志著，黃士軒譯，日本正當防衛論之新開展，月旦法學雜誌，177 期，頁 165、168-170（2010 年）。

然趙女並未面臨現在不法侵害，其刺殺行為就沒有適用刑法第23條但書的餘地。在不構成誤想防衛或禁止錯誤的情形下，趙女殺害賈男可能存在的混亂、恐懼或驚慌情緒，導致其行為控制力降低，只能被當成量刑減輕事由。相對於此，少數文獻主張，本條但書之減免刑罰理由在於期待可能性減低，其程度與客觀上防衛情狀之存否無關，況且後階段的行為是延續先前合法的防衛行為，而不是出於新犯意而積極侵害他人，故宜與先前的防衛行為合併觀察，因此亦適用於延展型防衛過當¹²⁰。按照這個立場，趙女的殺人行為仍可適用刑法第23條但書而減免其刑。

通說將減免罪責之防衛過當限縮適用在「強度型防衛過當」，有兩個理由。第一個理由是，「防衛過當」在概念上係以存在防衛權為前提，在侵害已經結束之後就無所謂行使防衛權，更沒有逾越行使防衛權尺度的過當問題，所以不包括「延展型防衛過當」在內¹²¹。第二個理由是，通說認為此處的減免刑罰理由在於行為不法與罪責程度的減輕¹²²。亦即，在強度型防衛過當，防衛行為固然超出尺度，但是既是在防衛情狀存在時所為，仍然在一定程度上發揮保全法益的效果，使其不法內涵低於單純侵害法益的行為，而此種低度不法的行為加上防衛情狀的迫切性，也同時使得期待行為人遵守防衛尺度的可能性降低。然而，「延展型防衛過當」行為，是在防衛情狀不存在的情況下所為，無論如何已經沒有保全法益的成效，充其量只能說，已經過去的迫切防衛情狀繼續影響行為人的情緒，以致於較難期待行為人馬上停止伴隨而來的侵害行為。因此，「延展型防衛過當」欠缺不法減輕的特徵，沒有適用刑法第23條但書的餘地。

¹²⁰ 許恒達（註119），頁35。

¹²¹ *Murmann* (Fn. 54), § 26 Rn. 82; *Schmidhäuser* (Fn. 50), 8/29.

¹²² *Jescheck/Weigend* (Fn. 24), § 45 I. 4; *Murmann* (Fn. 54), § 26 Rn. 82; *Gropp* (Fn. 23), § 7 Rn. 84 f.

儘管如此，本文仍然認為少數說的結論值得贊同。首先，「防衛過當」的法條文義可以包括所有行為人一度有正當防衛權卻逾越其權利界限的情況，不論是防衛行為逾越強度的界限，或是行為逾越防衛情狀的時間界限，都可以被稱為防衛過當¹²³。因此，防衛過當的概念並不排除防衛行為延續到侵害結束之後的情形。其次，「防衛過當」的法律效果不是一概免刑，而是由法官在個案裁量減輕或免除其刑，再加上立法者並未規定此處減免其刑的實質基礎為何，所以本但書的適用對象其實未必要兼具不法與罪責減輕的特徵。換言之，適用本條但書的防衛過當，固然是以強度型防衛過當為主要類型，但是在其他防衛過當的類型中，凡是不法或罪責程度有所降低而存在減免其刑餘地者，亦得適用本條但書，再由法官裁量減免。仔細觀察可知，延展型防衛過當的不法固然沒有減輕，但是其期待可能性減輕的原因及程度，其實與強度型防衛過當類似，只不過是作用時間點較晚而已。亦即，防衛情狀所造成的心理混亂、恐懼或驚慌，如果是在防衛情狀存在時就已經發揮作用，其結果就是造成防衛行為逾越尺度，如果是在防衛情狀結束之後才發揮作用，其結果就是造成行為人在防衛行為之後立即接續採取侵害行為¹²⁴。基此，儘管延展型防衛過當的不法程度高於強度型防衛過當，但是二者的罪責減輕程度則是相當，故宜將其納入刑法第23條但書的適用範圍。二者的差別僅在於，強度型防衛過當兼具不法及罪責減輕的性質，個案中裁量減輕刑罰的幅度較大，免除刑罰的可能性較高，而延展型防衛過當僅具有罪責減輕的性質，減輕刑罰的幅度較低，僅在極端例外時才有免除刑罰的機會。但是，無論如

123 參考 *Klaus Geppert*, Notwehr und Irrtum. Putativnotwehr, intensiver und extensiver Notwehrexzess, Putativnotwehrexzess, Jura 2007, S. 33 (38); *Engländer* (Fn. 21), § 33 Rn. 5; *Kindhäuser*, LPK-StGB (Fn. 26), § 33 Rn. 7; *Rengier* (Fn. 23), § 27 Rn. 19; *Otto* (Fn. 40), § 14 Rn. 23; *Köhler* (Fn. 25), S. 424; *Wessels/Beulke* (Fn. 54), Rn. 447.

124 *Rengier* (Fn. 23), § 27 Rn. 19; *Roxin* (Fn. 23), § 22 Rn. 88; *Schramm* (Fn. 54), S. 144 f.

何，從部分學說堅持僅在法律明文時才能適用無期待可能性概念¹²⁵來看，將延展型防衛過當納入本條但書之適用，也有助於罪責原則的實現。

就本案而言，趙女殺害賈男的行為，如果是延續先前面臨防衛情狀而生的混亂、恐懼或驚慌所致，而不是此種情緒消失後才另起殺意，其罪責減輕的原因及程度即與強度型防衛過當相當，應適用刑法第23條但書裁量減免其刑。剩下要注意的是，趙女是在認知防衛情狀結束之下持刀刺殺（所謂有意識的防衛過當），已知法益受威脅的情狀已經解除，相對而言，仍然可以期待她不受恐懼或驚慌的情緒所控制而放棄刺殺行為，所以只有在極端例外的時候，法院才得以免除其刑¹²⁶。

柒、結論

趙岩冰殺夫事件是改善移民婦女權益的契機，也是正當防衛理論的本土試金石。本案儘管已經判決定讞，但是所遺留的事實疑義，使我們無法對於趙女的刑責做出終局的認定。不過，本文的目的也不在於重新審視趙女的刑責如何，而是希望指出本案所存在的正當防衛難題及其解決方向，作為將來司法實務的參考。具體而言，本案的正當防衛難題及其解決之道如下：

一、侵害概念必須做目的性限縮。恐嚇行為固然是對他人意思自由或心理安全感的侵害，但是本質上是使他人恐懼將來不法侵害的發生，如果將恐嚇行為本身視為不法侵害，將會使侵害現在性之限制功能被架空，故應自始將其排除在防衛適格之侵害以外。（本

¹²⁵ 僅參考林鈺雄（註6），頁308。反對見解：黃榮堅（註48），頁625-627。

¹²⁶ 參考 Rengier (Fn. 23), § 27 Rn. 26.

文肆、一)

二、侵害現在性係以特定法益客體陷入具體危險為標準。侵害現在性必須在被害人有效保護利益以及侵害者承擔錯誤風險之間取得平衡，採取有效防衛理論或承認正當防衛類似情狀的學說，導致潛在侵害者所承擔的風險過大。在我國的正當防衛架構下，受虐婦女症候群對於防衛者可能造成的特殊認知及反應，已有充分多元的方式來處置，沒有必要概括地為受虐婦女創設一個特殊的侵害現在性標準，否則會導致個案不正義及不平等的後果。(本文肆、二)

三、防衛手段之必要性判斷必須貼近現實，法院尤其必須詳細論證，較輕微的替代防衛手段有無可靠的防衛效果。我國實務的現行運作忽略此事，迫使被害人承擔可能防衛無效的風險，實際上架空防衛者的正當防衛權。(本文伍、一)

四、防衛手段之社會倫理限制，不僅違反罪刑法定原則，其實質正當性亦有待就個別類型加以檢討。與本案相關的「緊密的個人關係」(主要是婚姻及家庭成員)，通說基於其彼此居於保護者保證人地位，或是互負特殊的連帶義務，或為了保護婚姻與家庭制度等理由，認為正當防衛之制度目的必須退讓，並無說服力。未來不應將「緊密的個人關係」承認為獨立的社會倫理限制類型。(本文伍、二)

五、防衛過當的適用對象，應包括強度型防衛過當及延展型防衛過當在內，由法官依個案情節裁量減輕或免除其刑。(本文陸)

基此，如果趙女有受虐婦女症候群，有必要在正當防衛的判斷上考量其特殊心理及反應模式，被告的辯護策略及法院判決的著力點，不應是變更防衛情狀的判斷標準，而是應該援引罪疑唯輕原則來假定趙女生命面臨現在不法侵害，然後更詳細地審視，趙女有無其他同樣可靠但是更輕微的替代防衛手段，以致於其防衛手段係出

於必要。如果答案是否定的，那麼也可以進一步審視，趙女的特殊心理及反應模式，是否導致她誤認沒有其他替代防衛手段可資運用，或是其混亂、恐慌的心理致使其防衛過當行為達到免除罪責的程度。

參考文獻

1. 中文部分

- 王皇玉（2004），竊盜被害人之贓物追回權與正當防衛——評最高法院九十一年度台上字第四〇〇三號判決，月旦法學雜誌，107期，頁233-247。
- （2011），正當防衛的始點，月旦法學教室，105期，頁28-29。
- 李佳玟（2005），女性犯罪責任的敘事建構——以鄧如雯殺夫案為例，臺大法學論叢，34卷6期，頁1-56。
- 李佳玟發言，賴芳玉主持（2008），「從家暴受虐婦女正當防衛殺人案探討受虐婦女經驗及女性主義法學於司法實踐之可能性」座談會紀錄，全國律師，12卷2期，頁71-75。
- 佐伯仁志著，黃士軒譯（2010），日本正當防衛論之新開展，月旦法學雜誌，177期，頁162-175。[佐伯仁志（2010），日本における正当防衛論の新たな展開，月旦法學雜誌，177期，頁145-161。]
- 余振華（2010），刑法違法性理論，2版，臺北：自版。
- 林山田（2008），刑法通論（上），10版，臺北：自版。
- （2008），刑法通論（下），10版，臺北：自版。
- 林志潔（2009），復仇的女王蜂？精神異常的弱女子？——由女性主義法學方法評析最高法院相關裁判，台灣法學雜誌，126期，頁33-49。
- 林孟皇（2012），婚姻移民與家庭暴力情境下殺夫行為的法律適用——評最高法院100年度台上字第2341號刑事判決，法令月刊，63卷5期，頁25-62。
- 林鈺雄（2014），新刑法總則，4版，臺北：自版。

- 吳耀宗(2012)，此郎非狼，月旦法學教室，122期，頁27-29。
- 柯耀程(2000)，正當防衛界線之認定，月旦法學雜誌，60期，頁85-97。
- 高金桂(2010)，義憤殺人罪與正當防衛——臺灣高等法院九十六年度上訴字第四四八九號判決，月旦裁判時報，2期，頁118-123。
- 徐育安(2012)，當場激於義憤，月旦法學教室，122期，頁30-32。
- 張天一(2001)，對正當防衛受社會道德限制之再檢討——以正當防衛阻卻違法之實質根據為中心，刑事法雜誌，45卷4期，頁71-123。
- (2002)，正當防衛之成立要件與防衛過當之處置方式(下)，刑事法雜誌，46卷2期，頁66-97。
- (2011)，兩岸正當防衛與防衛過當規定之比較，收於：黃陽壽、王煦棋、張天一、胡博硯編，中國大陸法制研究——第十九輯，頁141-196，臺北：司法院。
- 許恒達(2012)，延展型過當防衛，月旦法學教室，114期，頁33-35。
- 陳俊榕(2013)，論「挑唆防衛」，國立中正大學法學集刊，39期，頁73-112。
- 黃常仁(2009)，刑法總論，2版，臺北：自版。
- 黃榮堅(2000)，論正當防衛，收於：刑罰的極限，頁81-118，臺北：元照。
- (2012)，基礎刑法學(上)，4版，臺北：元照。
- (2012)，基礎刑法學(下)，4版，臺北：元照。
- 黃惠婷(2001)，正當防衛之現在不法侵害，台灣本土法學雜誌，23期，頁136-141。
- (2001)，正當防衛之防衛行為，台灣本土法學雜誌，29期，頁133-139。

賴芳玉等（2008），「從家暴受虐婦女正當防衛殺人案探討受虐婦女經驗及女性主義法學於司法實踐之可能性」座談會紀錄，全國律師，12卷2期，頁55-81。

劉宏恩（1997），婚姻暴力受虐婦女殺夫之責任能力與違法性問題（下）——法律心理學之觀點，月旦法學雜誌，20期，頁95-101。

劉幸義（1994），罪刑法定主義的理論與實務批判（上），刑事法雜誌，38卷5期，頁41-86。

鄭逸哲（2001），罪刑法定主義七十年，收於：余振華、林山田、林東茂、柯耀程、許玉秀、黃朝義、鄭善印、鄭逸哲著，刑法七十年之回顧與展望紀念論文集（一），頁77-107，臺北：元照。

薛智仁（2002），參與群毆行為之處罰基礎與立法，臺北：學林。
——（2011），不法侵害之現在性與著手實行——最高院99台上5562，台灣法學雜誌，182期，頁182-188。

2. 外文部分

Amelung, Knut (1982), Das Problem der heimlichen Notwehr gegen die erpresserische Androhung kompromittierender Enthüllung, GA, S. 381-403.

Baumann, Jürgen/Weber, Ulrich/Mitsch, Wolfgang (2003), Strafrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl., Bielefeld: Giesecking Verlag.

Bitzilekis, Nikolaos (1984), Die neue Tendenz zur Einschränkung des Notwehrrechts, Berlin: Duncker & Humblot.

Eggert, Matthias (2001), Chantage—Ein Fall der Beschränkung des Notwehrrechts?, NSTZ, S. 225-231.

Engländer, Armin (2013), Kommentierungen zu Vor §§ 32 ff., §§ 32, 33, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, München: Vahlen, Vor §§ 32 ff.-33.

- Erb, Volker (1996), Die Schutzfunktion von Art. 103 Abs. 2 GG bei Rechtfertigungsgründen. Zur Reichweite des Grundsatzes „nullum crimen sine lege“ unter besonderer Berücksichtigung der „Mauerschützen“-Fälle und der „sozialethischen Einschränkungen“ des Notwehrrechts, ZStW 108, S. 266-299.
- (2011), in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar Strafgesetzbuch, Band 1; §§ 1-51 StGB, 2. Aufl., München: C. H. Beck, §§ 32-34.
- (2011), Zur Aushöhlung des Notwehrrechts durch lebensfremde tatrichterliche Unterstellungen – Zugleich eine Besprechung von LG München I, Urt. V. 9. 1. 2009 – 1 Ks 121 Js 10459/08 („Fall Sven G.“), NSTZ, S. 186-193.
- (2011), Gegen eine Inflation der „sozialethischen Einschränkungen“ des Notwehrrechts, in: Kühl/Seher (Hrsg.), Rom, Recht, Religion, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 329-348.
- Fischer, Thomas (2011), Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 58. Aufl., München: C. H. Beck.
- Freund, Georg (2009), Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin u.a.: Springer.
- Frister, Helmut (1988), Die Notwehr im System der Notrechte, GA, S. 291-316.
- (2009), Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., München: C. H. Beck.
- Geppert, Klaus (2007), Notwehr und Irrtum. Putativnotwehr, intensiver und extensiver Notwehrexzess, Putativnotwehrexzess, Jura, S. 33-40.
- Gropp, Walter (2005), Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer.
- Günther, Hans-Ludwig (2009), Defensivnotstand und Tötungsunrecht, in:

- Böse/Sternberg-Lieben (Hrsg.), Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrechts: Festschrift für Knut Amelung zum 70. Geburtstag, Berlin: Duncker & Humblot, S. 147-157.
- Haverkamp, Rita (2006), Zur Tötung von Haustyrannen im Schlaf aus strafrechtlicher Sicht, GA, S. 586-604.
- Heinrich, Bernd (2012), Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.
- Herzog, Felix (2010), in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Strafgesetzbuch Nomos Kommentar, 3. Aufl., Baden-Baden: Nomos, § 32 StGB.
- Hillenkamp, Thomas (1995), In tyrannos-viktimologische Bemerkungen zur Tötung des Familientyrannen, in: Kühne (Hrsg.), Festschrift für Koichi Miyazawa, Baden-Baden: Nomos, S. 141-158.
- (2007), Vorbemerkungen zu den §§ 22 ff., in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Erster Band Einleitung; §§ 1 bis 31, 12. Aufl., Berlin: de Gruyter, Vor zu den §§ 22.
- Jäger, Christian (2013), Examens-Repetitorium Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., München: C. H. Beck.
- Jakobs, Günther (1992), Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- Jescheck, Hans-Heinrich/Weigend, Thomas (1996), Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.
- Kaspar, Johannes (2007), Gewaltsame Verteidigung gegen den Erpresser? Zu den Grenzen der Notwehr in den Fällen der sogenannten „Chantage“, GA, S. 36-47.
- Kindhäuser, Urs (2010), Strafgesetzbuch Lehr- und Praxiskommentar, 4. Aufl., Baden-Baden: Nomos.
- (2011), Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Baden-Baden:

Nomos.

- Köhler, Michael (1997), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Berlin/Heidelberg/New York: Springer.
- Kratzsch, Dietrich (1987), Der „Angriff“ – ein Schlüsselbegriff des Notwehrrechts. Zugleich eine Besprechung des Urteils BayObLG v. 9. 1. 1985 – R Reg 5 St 272/84, StV, S. 224-229.
- Krey, Volker/Esser, Robert (2011), *Deutsches Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.
- Kroß, Antje (2004), *Notwehr gegen Schweigegelderpressung*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Kühl, Kristian (2012), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 7. Aufl., München: Vahlen.
- Ludwig, Dominik (1991), „Gegenwärtiger Angriff“, „drohende“ und „gegenwärtige Gefahr“ im Notwehr- und Notstandsrecht, Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris: Peter Lang.
- Müller, Hennig Ernst (1993), Zur Notwehr bei Schweigegelderpressung (Chantage), NStZ, S. 366-368.
- (2006), Notwehr gegen Drohungen, in: Hoyer/Müller/Pawlik (Hrsg.), *Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag*, Heidelberg: C. F. Müller, S. 323-337.
- Murmann, Uwe (2011), *Grundkurs Strafrecht*, München: C. H. Beck.
- Nothafft, Susanne (1999), Himmel und Erde – Frauen in Gewaltverhältnissen und die Schwierigkeit, sie zu verteidigen, wenn sie ihren Peiniger töten, MschrKrim, S. 111-136.
- Novoselec, Petar (1997), Notwehr gegen Erpressung i. e. S. und Chantage, NStZ, S. 218-221.
- Otto, Harro (2004), *Grundkurs Strafrecht: Allgemeine Strafrechtslehre*, 7. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- Perron, Walter (2005), *Rechtsvergleichende Betrachtungen zur Notwehr*,

- in: Arnold/Burkhardt/Gropp/Heine/Koch/Lagodny/Perron/Walther (Hrsg.), *Menschengerechtes Strafrecht Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag*, München: C. H. Beck, S. 1019-1039.
- Rengier, Rudolf (2012), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 4. Aufl., München: C. H. Beck.
- Renzikowski, Joachim (1994), *Notstand und Notwehr*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Rienen, Rafael van (2009), *Die „sozialethischen“ Einschränkungen des Notwehrrechts*, Baden-Baden: Nomos.
- Rönnau, Thomas/Hohn, Kristian (2006), in: *Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafrechtsgesetzbuch Leipziger Kommentar*, Band 2, 12. Aufl., Berlin: de Gruyter, §§ 32-55.
- Roxin, Claus (2006), *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Band I, 4. Aufl., München: C. H. Beck.
- Scherenberg, Carl-Friedrich von (2009), *Die sozialethischen Einschränkungen der Notwehr*, Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris: Peter Lang.
- Schmidhäuser, Eberhard (1975), *Strafrecht Allgemeiner Teil: Lehrbuch*, 2. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.
- (1984), *Strafrecht Allgemeiner Teil: Studienbuch*, 2. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.
- Schramm, Edward (2011), *Ehe und Familie im Strafrecht*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Schroeder, Friedrich-Christian/Verrel, Torsten (2011), *Strafprozessrecht*, 5. Aufl., München: C. H. Beck.
- Schroth, Ulrich (1984), *Notwehr bei Auseinandersetzungen in engen persönlichen Beziehungen*, NJW, S. 2562-2564.
- Schünemann, Bernd (1985), *Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft nach der Strafrechtsreform im Spiegel des*

- Leipziger Kommentars und des Wiener Kommentars, 1. Teil: Tatbestands- und Unrechtslehre, GA, S. 341-380.
- Seelmann, Kurt (2009), Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Basel: Helbing.
- Stemler, Patrick (2010), Die Notwehr, ZJS, S. 347-356.
- Stratenwerth, Günter/Kuhlen, Lothar (2011), Strafrecht Allgemeiner Teil I, 6. Aufl., München: Vahlen.
- Suppert, Hartmut (1973), Studien zur Notwehr und „notwehähnlichen Lage“, Bonn: Röhrscheid.
- Voss, Almuth (2013), Die Notwehrsituation innerhalb sozialer Näheverhältnisse, Berlin: Duncker & Humblot.
- Walther, Susanne (2003), Anmerkung zu BGH, Urteil v. 18. 4. 2002 – 3 StR 503/01, JZ, S. 52-56.
- Welke, Wanja Andreas (2004), Der „Haustyrannenmord“ im deutschen Straftatsystem. Diskutiert unter Einbeziehung neuerer Tendenzen im common law, ZRP, S. 15-20.
- Wessels, Johannes/Beulke, Werner (2012), Strafrecht Allgemeiner Teil, 42. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.
- Wiegand, Marc André/Zabel, Benno (2004), Zur Notwendigkeit der Präzisierung des Merkmals der „Gegenwärtigkeit“ des Angriffs im Rahmen der Dogmatik zu § 32 Abs. 2 StGB, HRRS, S. 202-211.
- Wohlers, Wolfgang (1999), Einschränkungen des Notwehrrechts innerhalb sozialer Näheverhältnisse, JZ, S. 434-442.
- Zieschang, Frank (2003), Einschränkung des Notwehrrechts bei engen persönlichen Beziehungen?, Jura, S. 527-532.

Problems of the Right to Self-Defense in Domestic Violence:

The Case of Zhao Yan Bing

*Chih-Jen Hsueh**

Abstract

Following the 1993 mariticide case of Deng Ruwen, the 2006 case of Zhao Yan Bing once again highlights the difficulties in the application of self-defense in domestic violence. Both of the district court and the high court judgments referred to battered woman syndrome to revise the criteria of imminence in self-defense, and thereby increased the applicability of self-defense in domestic violence. As such, the courts' decisions in this case were hailed as the emergence of gender-awareness in Taiwan's criminal justice. However, this article has reservations in this regard. On the one hand, in light of the sharpness of right to self-defense, this article argues for the strict construction of the defense status. In addition to the purpose restrictions on the concept of infringement, whether the danger was in fact imminent should be examined under the criteria of specific hazard. The special experience of battered women is but a psychological state of affairs on the part of the defenders. Rather than creating a special criterion of imminence for battered women, the court should take into consideration all the relevant facts, including the psychological state and the psychological reaction of the defender, in determining whether a given conduct is qualified as self-defense. On the other hand, this article argues for the relaxation of the restrictions on defense measures, especially when it comes to the necessity requirement for the means of self-defense. The court should not force the defender to take a defense measure that would expose him/her to additional risks and

* Assistant Professor, College of Law, National Taiwan University.

thereby render his/her right to self-defense infeasible. Furthermore, this article argues against the prevailing doctrinal theory requiring that self-defense measures meet an additional criterion of appropriateness when intimate personal relationship is at stake. Such requirement is unjustified and has violated the *nulla poena sine lege* principle. In sum, the right approach to respect the special experience of battered women is to apply the law with due consideration of their actual situation, as opposed to creating a special judicial standard applicable only for their self-defenses.

KEYWORDS: self-defense, the Concept of infringement, imminent threat, specific hazards, battered woman syndrome, defense necessity, defense decency, intimate personal relationship, guarantor status, unjustifiable defense.